노동법상 근로자·사용자 개념 확대를 둘러싼 쟁점과 입법적 과제

이승욱*

목 차

Ⅰ. 유형별 접근의 필요성
Ⅱ. 현행법상 근로자 및 사용자 개념의 해석과 한계
Ⅲ. 입법적 제안에 대한 검토
Ⅳ. 새로운 접근을 위한 출발점

Ⅰ. 유형별 접근의 필요성

1. 근로자 및 사용자 개념이 문제되는 유형

1997년 금융위기 이후 기업의 구조조정을 통한 비용절감과 경쟁력 확보는 예외적인 현상이 아니라 일상이 되고 있다. 그 대표적인 수단 중 하나로서 근로자개념 또는 사용자개념의 조작을 통하여 노동법상 사용자 책임을 회피하려는 움직임을 들 수 있는데, 이를 유형화시키면 다음과 같이 분류할 수 있다.

첫째, 노무제공을 주된 사업내용으로 하는 기업에서 종래 근로자에 의해 수행되던 업무를 도급이나 위임계약을 체결한 자로 하여금 수행하도록 하는 형태로 사업을 운영하는 경향이 뚜렷하게 나타나고 있다. 처음

투고일 2014.02.20., 심사일 2014.02.28, 게재확정일 2014.03.10.
* 이화여자대학교 법학전문대학원 교수.

www.kci.go.kr

부터 개인에게 도급이나 위임을 통한 노무제공을 받는 형태로 사업을 운영하는 경우도 많다. 이러한 유형은 종래 이른바 특수형태고용종사자로 논의되는 문제로서, 기업의 입장에서는 노무지휘명령권을 사실상 상당 부분 행사하여 종래와 같은 사업 체제를 그대로 유지하면서도 인력수요에 탄력적으로 대응할 수 있고 인건비도 줄일 수 있기 때문에 개인에 대한 노무도급형태의 근로가 급속하게 확대되고 있다.[1] 근로계약에 갈음하여 도급이나 위임의 계약형식을 취하고 있기 때문에 사용자는 노동법상 사용자로서의 책임을 회피할 수 있는 여지가 발생한다. (유형 1)

둘째, 근로자파견이나 업무의 도급·위임 현상은 새로운 업무에 대해 행해지는 것이 아니라 대부분 기존의 업무, 즉 정형적·표준적 업무로서 직접 고용하는 근로자에 의해 굳이 수행되지 않아도 무방한 업무를 대상으로 이루어지고 있으나, 이러한 업무 역시 기업운영에는 불가결한 것이기 때문에 원청회사나 사용기업이 어떤 형식으로든 업무의 수행에 관여하는 경우가 대부분이다. 바꾸어 말하면 원청회사나 사용기업은 통상의 업무를 그대로 유지하고 비용도 절감하여 이익을 향유하면서도 자신들이 원래 부담하여야 할 노동법상의 사용자책임을 수급회사나 파견기업에게 전가함으로써 추가적인 이익을 합법적으로 향유하고 있다. 파견근로자에 대해서는 합법적으로, 수급회사의 근로자에 대해서는 실질적으로 근로자에 대한 지휘감독을 사실상 종전과 마찬가지로 행하면서도 사용자로서의 책임은 피할 수 있는 것이다. (유형 2)

셋째, 지주회사나 모회사는 자회사의 인사노무관리를 사실상 결정하거나 그것에 상당한 영향력을 미칠 수 있는 지위에 있다. 자회사는 지주회사나 모회사의 지시에 따르지 않을 수 없고, 자회사 근로자나 노동조합의 요구를 결정할 권한이나 지위에 있지 않은 경우가 많다. 기업집단을 이루는 경우 핵심사업 이외의 사업을 정리하는 수단으로 자회사를 이용

---

1) 2011년 8월 기준 정부 추계에 의하면 이러한 유형에 종사하는 자의 수는 61만 4천명에 이르고 있다는 견해(강신철, "비정규직 범위와 규모에 관한 새로운 고찰", 『산업관계연구』 제22권 제1호, 한국노사관계학회, 2012, 70쪽)가 있고, 2013년 현재 정부의 추산에 따르면 115만 명이라는 보도(한국일보 2013.9.12.자 http://news.hankooki.com/lpage/society/201309/h2013091120395321950.htm)도 있다

www.kci.go.kr

하는 경우도 발생할 수 있으나, 지주회사나 모회사는 법인격이 다르다는 이유로 사용자책임은 면할 수 있다. (유형 3)

넷째, 합병이나 영업양도 등 기업변동이 발생할 경우, 인수회사나 합병회사 등은 계약 발효 이전에 피인수예정회사나 흡수예정회사 등에 대해 일정한 인원정리를 요구하는 경우가 있다. 근로기준법(이하 '근기법') 제24조 제1항 2문은 "경영악화를 방지하기 위한 사업양도·인수·합병은 긴박한 경영상의 필요가 있는 것으로 본다"고 규정하고 있다. 이러한 규정 자체에 문제가 없는 것은 아니지만, 어쨌든 여기에서 상정하고 있는 상황은 해당 기업이 실시하는 정리해고의 경우이다. 그런데, 인수나 합병을 예정하고 있는 회사나 투자펀드의 요구나 지시로 인원정리 등 구조조정을 할 경우에는 인수나 합병 예정 회사 등은 피인수회사 등에 종사하는 근로자의 고용에 직접적인 영향을 미치면서도 법인격이 다르다는 이유로 노동법상의 책임을 면할 수 있다. 즉 기업변동시 근로관계의 승계를 둘러싼 노동법상의 문제와는 별도로, 피인수회사 등의 근로자의 고용에 일정한 영향력 내지 지배력을 행사할 수 있으나, 이에 대한 사용자책임은 지지 않는 상황이 발생하는 것이다. (유형 4)

이와 같이 최근 노무제공형태가 다양화됨에 따라 제기되는 문제의 핵심에는 노동법상 근로자개념 내지 사용자개념이 자리하고 있다. 형식적인 계약관계, 사용종속관계, 법인격을 전제로 한다면, 사용자는 종래와 같은 형태로 사업을 유지하고 큰 위험부담 없이 오히려 더 많은 이윤을 얻을 수 있는 이익을 누릴 수 있지만, 노동법상의 책임과 의무는 모두 회피할 수 있다. 반면 근로자는 이러한 현상으로 인한 혜택은 거의 없고 노동법상의 보호를 전부 또는 대부분 박탈당함으로써 노동법의 보호영역에서 사실상 배제당하는 부당한 결과가 발생한다.

2. 유형에 따른 특징

계약형식의 관점에서 보면, 유형 2, 3, 4는 모두 직접적인 사용자가 있기는 하지만, 실질적으로는 제3자에 의해 근로조건이나 고용이 결정되거나 영향을 받는다는 점에서 공통성이 있다. 즉 근로자의 사용자는 제3자

www.kci.go.kr

의 법적 또는 사실상의 지배력 하에 놓여 있는 경우가 많기 때문에 자신이 고용하는 근로자의 근로조건 등에 관하여 독자적으로 결정할 수 없는 경우가 대부분이다. 그러나 이 세 유형에서는 근로자를 고용하는 기업과 근로조건 등에 영향을 미치는 제3자가 별개의 법인격을 가지고 있는 점, 제3자는 직접적인 근로계약의 당사자가 아닌 점, 제3자는 근로조건 등에 관하여 직접적인 또는 간접적인 지배력이나 영향력을 행사하고 있음에도 불구하고 사용종속관계에서 요구하는 징표를 갖추지 못한 경우가 일반적이라는 점 등을 이유로 제3자의 사용자성은 통상적으로 인정되지 않는다.

그런데, 이 세 유형은 제3자가 행사하는 지배력이나 통제력의 정도와 범위가 상이하고 문제되는 상황이 다소 차이가 있기 때문에 일률적으로 접근하기는 어렵다. 유형 2에서는 제3자에 의한 노무지휘명령권 행사가 다른 유형에 비하여 '직접적'으로 이루어지고 근로조건의 결정 역시 마찬가지다. 따라서 유형 2는 제3자에게 사용자로서의 책임을 묻는 것이 상대적으로 용이하다. 반면, 유형 3에서는 지주회사나 모회사가 자회사를 통하여 주식지배를 통해 '간접적'으로 지배력을 행사하고, 구체적인 결정을 내리는 형식적인 주체는 자회사가 된다. 주식지배를 통한 간접적인 영향력 내지 지배력을 어떻게 평가하는가에 따라 사용자책임을 추급할 수 있는 가능성은 있지만, 자회사 근로자의 노무제공과정에서 구체적인 지휘명령권을 행사하거나 근로조건의 결정에 직접 관여하는 경우는 적기 때문에 제3자에 대해 사용자로서의 책임을 묻는 것이 상대적으로 더 어려우며, 설사 사용자로서의 책임을 인정한다고 하더라도 어떤 범위에서 인정할 것인가 하는 문제도 남는다. 이에 대해 유형 4는 '사실상'의 지배력을 행사하는 경우이다. 유형 3이 간접적인 지배력을 행사하고 제3자와 사용자 사이에 주식을 통한 법적인 지배관계가 성립하고 있는 데 대하여, 유형 4는 제3자와 사용자 사이에 어떠한 법률관계도 존재하지 않고 제3자가 행사하는 영향력은 기업변동과 관련한 거래에서 거래의 우위를 이용한 사실상의 압력에 그치기 때문에 제3자에 대해 사용자로서의 책임을 묻는 것은 매우 곤란하다는 점에서 차이가 있다.

법인격이 함께 문제되고 있는 앞의 유형들과 비교하면, 유형 1은 당사자간에 근로계약 자체가 존재하지 않는다는 점에서 차이가 있다. 계약의

www.kci.go.kr

형식은 도급이나 위임계약이지만, 사업주는 실질적으로 근로계약관계 하에서와 동일하거나 유사한 지휘명령권을 행사하여 사용종속관계를 구성하는 징표의 전부를 충족하거나 최소한 일부는 충족하는 경우가 대부분이다. 따라서 노무제공 상대방에 대해 사용자책임을 추급할 수 있는 가능성은 앞의 유형들에 비해 상대적으로 높은 편이지만, 만약 사용자성 또는 근로자성을 인정받지 못하면, 설사 사용종속관계의 징표 중 일부를 갖추고 있다고 하더라도 노동법상의 보호범위에서 완전히 배제되어 버리기 때문에 지위는 오히려 훨씬 불안정하다고 할 수 있다.[2)]

이상의 사례는 입구(threshold) 통제를 통한 노동법의 보호범위를 획정하여 온 지금까지의 법제도나 운용이 한계를 노정하고 있다는 것을 보여준다. 종래 노동법제가 상정하지 못하던 다양한 취업형태와 양상이 문제되고 있고, 기존 노동법제로는 해결하기 어려운 과제를 제시하고 있기 때문에, 노동법의 인적 적용대상과 계약형식이나 내용에 관한 규율 내용과 방법, 나아가 분쟁해결에 대해 새로운 관점과 새로운 방법론으로 대처하는 것이 필요한 시점이라고 판단된다.

이하에서는 이러한 문제점에 대해 기존의 판례나 학설이 어떻게 대응하고 있는지, 문제를 합리적으로 해결할 수 있는지를 검토한 뒤, 입법론으로 주장되고 있는 내용과 그 한계를 살펴보고, 향후 바람직한 방향을

---

2) 최근 지원이 대폭 강화되는 방향으로 개정된 '1인 창조기업 육성에 관한 법률'은 제조업, 출판·영상·방송통신 및 정보서비스업, 전문과학 및 기술서비스업, 사업시설관리 및 사업지원서비스업, 교육서비스업, 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업(동법 시행령 제2조 제1항 별표 1) 등 광범위한 지식서비스업과 제조업을 상시근로자 없이 영위하는 1인 또는 5인 미만의 공동사업자에 대하여(법 제2조 참조) 창업지원, 거래지원, 교육훈련지원, 기술개발지원, 아이디어 사업화, 홍보, 금융지원, 조세특례 등 야심찬 지원을 제도화하고 있다. 이 법에 근거한 거국적인 지원에 의해 1인 창조기업이 다수 설립되어 확산된다면 과연 이 법의 목적인 "국민경제의 발전에 이바지"(법 제1조)할 수 있을 것인가. 최소한 노동법적인 관점에서 보자면 유감스럽지만, 그럴 가능성 보다는 오히려 유형 1과 같은 형태의 노무도급현상을 양산할 가능성이 우려된다. 지식서비스업과 제조업 등 광범위한 분야에서 도급인과 수급인인 1인 창조기업 사이에 노무도급관계가 성립하여 도급인의 지휘명령 하에서 근로자와 유사한 노무를 제공하는 유형 1과 같은 형태로 진행될 여지가 많아 도급인의 노동법상 사용자책임이 문제될 가능성이 많기 때문이다.

www.kci.go.kr

제시하고자 한다.

Ⅱ. 현행법상 근로자 및 사용자 개념의 해석과 한계

1. 근로자 개념에 대한 판례의 해석: 유형 1에 대한 검토

1) 근로기준법상 근로자개념

(1) 1994년 이후

근기법상 근로자개념과 관련하여 대법원은 1994년 이후 일관하여 "근로기준법상 근로자에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 그 계약이 민법상의 고용계약이든 또는 도급계약이든 그 계약의 형식에 관계없이 그 실질에 있어 근로자가 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 여기서 종속적인 관계가 있는지 여부를 판단함에 있어서는 업무의 내용이 사용자에 의하여 정하여지고 취업규칙 또는 복무규정 등의 적용을 받으며, 업무수행과정에서도 사용자로부터 구체적, 개별적인 지휘·감독을 받는지 여부, 근로자 스스로가 제3자를 고용하여 업무를 대행케 하는 등 업무의 대체성 유무, 비품·원자재나 작업도구 등의 소유관계, 보수의 성격이 근로 자체의 대상적 성격이 있는지 여부와 기본급이나 고정급이 정하여져 있는지 여부 및 근로소득세의 원천징수 여부 등 보수에 관한 사항, 근로제공관계의 계속성과 사용자에의 전속성의 유무와 정도, 사회보장제도에 관한 법령 등 다른 법령에 의하여 근로자로서의 지위를 인정받는지 여부, 양 당사자의 경제·사회적 조건 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것"이라고 판단하고 있었고,[3] 이 문장은 근기법상 근로자 개념을 판단할 때 공식처럼 인용되고 있었다.[4]

---

3) 대법원 1994. 12. 9. 선고 94다22859 판결.

4) 대법원 1996. 7. 30. 선고 96도732판결; 대법원 1997. 12. 26. 선고 97다17575판결 등 다수. 이러한 판단구도는 산재보험법상의 근로자성 판단에도 그대로 통용되고 있다. 판례는 산재보험법은 "산재보험법상의 보험급여를 받을 수 있

www.kci.go.kr

근기법상 근로자성 판단에 관한 기본공식을 제시한 1994년 판결 이후 대법원은 이 기준에 의하여 유형 1에 속하는 것으로 볼 수 있는 자의 근로자성 여부를 판단한 사건에서 거의 일관하여 근기법상 근로자성을 부정하고 있다. 골프장경기보조원,[5] 레미콘기사,[6] 학습지교사,[7] 지입차주,[8] 보험모집인,[9] 지입중기차주인 기사,[10] 양복점의 재봉공,[11] 오토바이퀵서비스종사자,[12] 방문판매회사의 판매대리인,[13] 한국방송공사 드라마제작국에서 노무를 제공하는 외부제작요원[14] 등에 대해서 근로자성을 부정하였다. 그 부정의 주된 근거는 근로자로 볼 수 있을 정도의 인적 종속성을 결여하고 있는 것으로 요약할 수 있다.[15]

는 근로자에 대하여 '근로기준법상의 근로자'를 말한다고 규정하는 외에 다른 규정을 두고 있지 아니하므로 보험급여대상자인 근로자는 오로지 '근로기준법상의 근로자'에 해당하는지의 여부에 의하여 판가름 나는 것이고, 그 해당 여부는 그 실질에 있어 그가 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야"(대법원 1999. 2. 24. 선고 98두2201 판결) 한다고 하여, "산재보험법의 독자적인 입법목적"을 고려하지 않고 법조문(산재보험법 제4조 제2호)에 따라 근기법상 근로자개념을 그대로 차용하고 있다.

5) 대법원 1996. 7. 30. 선고 95누13432 판결.

6) 대법원 1995. 6. 30. 선고 94도2122 판결; 대법원 1997. 2. 14. 선고 96누1795 판결; 대법원 2003. 1. 10 선고, 2002다57959 판결.

7) 대법원 1996. 4. 26. 선고 95다20348 판결.

8) 대법원 1996. 11. 29. 선고 96누11181 판결; 대법원 2001. 4. 13. 선고 2000도4901 판결.

9) 대법원 2000. 1. 28. 선고 98두9219 판결.

10) 대법원 1997. 12. 26. 선고 97누16534 판결; 대법원 1998. 5. 8. 선고 98다6084 판결.

11) 대법원 2001. 8. 21. 선고 2001도2778 판결.

12) 대법원 2004. 3. 26. 선고 2003두13939 판결.

13) 대법원 2002. 7. 12. 선고 2001도5995 판결.

14) 대법원 2002. 7. 26. 선고 2000다27671 판결.

15) 이에 대하여 긍정한 예로는 광고수탁 및 광고료 수금업무에 종사하는 광고영업사원(대법원 2001. 6. 26. 선고 99다5484 판결), 자기소유버스를 수영장 사업주 명의로 등록하고 수영장 회원운송을 위한 기사로 일한 사례(대법원 2000. 1. 18. 선고 99다48986 판결)가 있으나, 이들 사건은 그 사실관계에서 사용자에 의한 지휘·통제권의 행사가 분명하게 나타나는 예외적인 사건이라고 할 수 있다.

www.kci.go.kr

요컨대 이 시기 대법원은 유형 1의 범주에 속하는 노무제공자에 대해서는 일관하여 근로자성을 부정하고 있다. 따라서 역설적으로 이러한 노무제공자의 근로자성에 관한 예측가능성은 확실하게 확보하고 있다고 할 수 있다. 이들에 대한 근로자성 부정은 형식적으로는 개별 사건의 사실관계에 기한 판단에서 기인하는 것으로도 볼 수 있으나, 실질적으로는 이러한 유형의 노무제공자에 관한 대법원의 정책적 판단이 이미 전제되어 있는 것은 아닌가 하는 의문을 배제하기 힘들다.

(2) 2006년 이후

1994년 이후 유지된 근로자성 판단공식은 2006년 판결[16] 이후 약간의 변용을 겪게 된다. 2006년 대법원은 위의 대법원 판결을 직접 인용하면서도 미묘하지만 중요한 변화를 보이고 있다. 이에 따르면 "근로기준법상의 근로자에 해당하는지 여부는 계약의 형식이 고용계약인지 도급계약인지보다 그 실질에 있어 근로자가 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 위에서 말하는 종속적인 관계가 있는지 여부는 업무 내용을 사용자가 정하고 취업규칙 또는 복무(인사)규정 등의 적용을 받으며 업무수행 과정에서 사용자가 상당한 지휘·감독을 하는지, 사용자가 근무시간과 근무장소를 지정하고 근로자가 이에 구속을 받는지, 노무제공자가 스스로 비품·원자재나 작업도구 등을 소유하거나 제3자를 고용하여 업무를 대행케 하는 등 독립하여 자신의 계산으로 사업을 영위할 수 있는지, 노무 제공을 통한 이윤의 창출과 손실의 초래 등 위험을 스스로 안고 있는지와, 보수의 성격이 근로 자체의 대상적 성격인지, 기본급이나 고정급이 정하여졌는지 및 근로소득세의 원천징수 여부 등 보수에 관한 사항, 근로 제공 관계의 계속성과 사용자에 대한 전속성의 유무와 그 정도, 사회보장제도에 관한 법령에서 근로자로서 지위를 인정받는지 등의 경제적·사회적 여러 조건을 종합하여 판단하여야 한다"고 하면서 "다만 기본급이나 고정급이 정하여졌는지, 근로소득세를 원천징수하였는지, 사회보장제도에 관하여 근로자로 인정받는지 등의 사정은, 사용자가 경제적으로

16) 대법원 2006. 12. 7. 선고 2004다29736 판결.

www.kci.go.kr

우월한 지위를 이용하여 임의로 정할 여지가 크다는 점에서, 그러한 점들이 인정되지 않는다는 것만으로 근로자성을 쉽게 부정하여서는 안 된다"고 판시하고 있다. 이 판결에서 취한 대법원의 입장은 이후에도 유지되어 현재에 이르고 있다.

이러한 변화는 유형 1에 속하는 범주의 노무제공자에 대해 특히 의미를 가진다. 이러한 형태의 노무제공자는 기본급이나 고정급이 정하여지지 않은 보수형태를 가지고 근로소득세를 징수당하지 않으며 사회보험법상 "자영업자"로[17] 취급받는 경우가 대부분일 뿐만 아니라, 노무제공 상대방으로부터 업무의 세세한 부분까지 통제받는다고 할 수는 없으나 "상당한" 통제를 받는다. 따라서 이러한 요소들에 대하여 근로자성 인정에 상대적으로 낮은 중요성을 부여한다면 근기법상 근로자로서의 지위가 반드시 부정되지 않을 수도 있기 때문이다. 특히 유형 1에 속하는 노무제공자의 대부분은 "독립하여 자신의 계산으로 사업을 영위할 수 있으며 노무 제공을 통한 이윤의 창출과 손실의 초래 등 위험을 스스로 안고 있는" 자영업자로서의 속성을 가진다고 할 수는 없다. 따라서 이러한 근로자성 판단 요소 사이의 상대적 의미 변화는 유형 1에 속하는 범주의 노무제공자의 근로자성 인정에 상당한 영향을 미치고 있다. 예컨대 채권추심업무위탁계약을 체결한 촉탁직 채권추심원,[18] 화물운송업을 영위하는 회사와 화물자동차운전용역(도급)계약을 체결한 운송기사,[19] 방송국 VJ,[20] 정수기렌탈회사의 지점장,[21] 법무법인의 변호사[22] 등에 대해서는 위 2006년 대법원 판결문의 근로자성 판단기준을 인용하면서 근기법상 근로

17) 사회보장기본법 제28조, 국민건강보험법 제4조 등 참조.
18) 대법원 2010. 4. 15. 선고 2009다99396 판결. 반면 채권추심원에 대한 근로자성을 부정한 예도 있다(대법원 2009. 5. 14. 선고 2009다6998 판결).
19) 대법원 2010. 5. 27. 선고 2007두9471 판결. 이 사건은 지입차주에 관한 사건은 아니고, 차량을 회사가 소유하고 있는 점에서 종전 사례와는 사실관계를 달리 한다.
20) 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010두10754 판결.
21) 대법원 2012. 5. 10. 선고 2010다81407 판결. 그러나 정수기에 대한 필터교환 등을 담당하는 이른바 코디에 대해서는 근기법상 근로자성을 부정하고 있다(대법원 2012. 5. 10. 선고 2010다5441 판결).
22) 대법원 2012. 12. 13. 선고 2012다77006 판결.

www.kci.go.kr

자로 인정하고 있다.

2) 노조법상 근로자개념

이에 대하여 노동조합 및 노동관계 조정법(이하 '노조법')상의 근로자성 여부가 문제된 사건은 근기법상 근로자성이 문제된 사건에 비하여 상대적으로 적다.[23] 노조법상 근로자의 판단이 문제된 사건에서는 대법원이 사용종속성 판단기준을 1994년 판결이나 2006년 판결과 같이 상세히 설시하면서 판단한 사례는 없다. 상대적으로 상세한 기준을 제시하는 캐디사건에서는 업무수행에 있어서 지시구속성, 보수의 대가성, 전속관계 등 세 가지 요소를 고려하여 "종속적 노동관계에 있다"고 인정하고 있을 뿐이다.[24] 다만 "여기서 사용자라 함은 근로자와의 사이에 사용종속관계가 있는 자를 말한다고 할 것이다"고 하는 것이 노조법상 근로자성 판단을 위한 원칙적인 기준이라고 할 수 있다.[25] 여기에서 말하는 사용종속관계가 근기법상의 사용종속관계와 동일한지 여부는 현재로서는 명확한

23) 농수산물도매시장의 지정도매인으로 지정되어 건해산물을 수탁판매하는 회사에 대해 노무를 제공하는 조합원을 가지는 항운노조는 적법한 노동조합이 아니라고 한 사례(대법원 1992. 5. 26. 선고 90누9438 판결); 한전수금원이 한전과의 관계에서 노조를 설립할 수 있는 관계에 있지 않다고 한 사례(대법원 1970. 7. 21. 선고, 69누152 판결); 개별 하역회사의 항운노조에 대한 단체협약체결권자의 지위를 부정한 사례(대법원 1997. 9. 5. 선고 97누3644 판결); 캐디에 대해 노조법상 근로자개념을 인정한 사례(대법원 1993. 5. 25. 선고 90누1731 판결); 일시적으로 실업 상태에 있는 자나 구직중인 자에 대해 노조법상 근로자개념을 인정한 사례(대법원 2004. 2. 27. 선고 2001두8568 판결); 레미콘 차주 겸 운송기사에 대해 노조법상 근로자성을 부정한 사례(대법원 2006. 5. 11. 선고 2005다20910 판결; 대법원 2006. 6. 30. 선고 2004두4888 판결); 준공되지 않은 항만에서 하역근로자로 일할 자들에 대해 노조법상 근로자성을 긍정한 사례(대법원 2011. 3. 24. 선고 2007두4483 판결) 등이 있다. 한편 노조법상 근로자 개념이 문제된 사안은 아니지만, 노조가 설립되어 있는 경우에도 근기법상의 근로자 개념은 별도로 판단하여야 한다고 하여 근기법상 근로자개념을 부정한 사례(대법원 1980. 12. 9. 선고, 79다2147 판결)도 간접적으로는 노조법상 근로자개념의 확정에 간접적으로는 영향을 미친다고 할 수 있다.

24) 대법원 1993. 5. 25. 선고 90누1731 판결.

25) 대법원 1997. 9. 5. 선고 97누3644 판결.

www.kci.go.kr

것은 아니다.

서울여성노동조합사건에서 노조법상 '근로자'에는 특정한 사용자에게 고용되어 현실적으로 취업하고 있는 자뿐만 아니라, 일시적으로 실업 상태에 있는 자나 구직중인 자도 노동3권을 보장할 필요성이 있는 한 그 범위에 포함된다고 보고 있다.[26] 그러나 이 판결에서도 법의 목적에 따라서 "일시적으로 실업 상태에 있는 자나 구직중인 자"가 노조를 설립할 여지를 인정하고 있을 뿐, 노조법상 근로자에 해당하는지 여부를 판단할 때 고려하여야 할 요소가 적극적으로 제시되어 있지는 않다. 즉 "특정한 사용자에게 고용되어 현실적으로 취업하고 있는 자"에 대한 사용종속성 판단이 근기법과 동일한 기준에 따라 이루어지는지 아니면 별도의 기준이 적용되는지에 관한 대법원의 입장을 이 판결에서 명확히 알 수는 없다.[27]

이와 관련하여, 한 하급심은[28] 노조법상 근로자의 개념, 특히 사용종속관계의 판단에 중요한 문제를 제기하고 있다. 이에 따르면, "판례의 지배적인 입장"[29]은 근로기준법상의 근로자 개념과 노동조합및노동관계조

---

26) 대법원 2004. 2. 27. 선고 2001두8568 판결.

27) 철도하역근로자의 퇴직금청구사건 판결(대법원 1980. 12. 9. 선고, 79다2147 판결)은 근기법상 근로자에는 해당하지 않지만 단체협약을 체결하는 노동조합의 조합원이라는 점을 부정하지 않아, 근기법상 근로자에는 해당하지 않지만 "현실적으로 취업하고 있는 자"도 노조법상 근로자에는 해당할 수 있다는 여지를 시사하고 있으나, 이를 일반화할 수 있는지는 명확하지 않다. 또한 아직 준공되지 않은 항만에서 하역 관련 사업장의 근로자가 되려고 하는 자를 조합원으로 하여 노동조합설립신고를 한 사건에서 대법원은 "노동조합법 제2조 제1호 및 제4호 단서 (라)목의 '근로자'라 함은 특별한 사정이 없는 한 특정한 사용자에게 고용되어 현실적으로 취업하고 있는 자에 한정하는 것이 원칙"이라고 하면서도, 지역별·업종별 노동조합의 성격, 하역노동의 특수성, 단계적 준공절차를 거치는 항만공사의 특성, 노조가 설립되는 경우 조합원의 취업은 그 시기를 특정할 수 없을 뿐 취업 자체는 확실시된다는 점 등을 고려하여 이 사건 근로자를 단순한 실업자나 구직자와 구별된다고 하여 근로자성과 노조 설립을 긍정하고 있다(대법원 2011. 3. 24. 선고 2007두4483 판결).

28) 서울행정법원 2001. 9. 4 선고 2001구6783 판결의 각주 6.

29) 그러나 이 판결이 "판례의 지배적인 입장"이라고 하는 근거가 되는 대법원 1970. 7. 21 판결 69누152에서는 "노동조합의 구성원인 근로자와 사용자 사이에는 고용에 따른 종속관계가 있어야 하고 이러한 관계가 없는 자는 노동

www.kci.go.kr

정법상의 근로자 개념을 동일하게 파악하는 것이라고 하고 있다.[30]

그러나 이 입장에는 찬성하기 어렵다. 근로자성 판단기준을 제시한 1994년 대법원 판결이나 2006년 대법원 판결은 근로자성 확인을 위한 공식으로서 그 이후 일관하여 관련 대법원 판결에서 이용되고 있으나, 그것은 근기법상의 근로자개념을 판단하는 사건에서만 명시적으로 인용되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.[31] 즉 근기법상 근로자개념이 문

조합법이 정한 적법한 노동조합을 조직할 수 있는 근로자가 될 수 없다"고 판시하고 있을 뿐이기 때문에 대법원이 여기에서 말하는 "고용에 따른 종속관계"가 근기법상의 그것과 동일하다고 단언할 수는 없다.

30) 이 판결에서는 부당노동행위사건에서 골프장경기보조원의 근로자성을 부정하면서 "노동조합법상의 근로자에 관한 정의는 근로기준법 제14조의 근로자 정의……와 비교하여 볼 때 '사업 또는 사업장'을 요건으로 하지 않는 점에서 일응 차이가 있는 듯이 보이나, 근로기준법이나 노동조합법이나 종속노동의 대가로 생활을 영위하는 자의 보호를 목적으로 하는 점에서는 차이가 없고, 다만 근로기준법은 특정의 사용자와 근로자의 현실적인 근로관계를 그 규율대상으로 하는 반면에('사업 또는 사업장'을 요건으로 한다) 노동조합법은 그와 같은 현실적인 근로관계에 있어서의 근로조건의 유지·개선 등을 효과적으로 달성할 수 있는 근로자의 자주적인 단결권 등의 보장을 그 입법목적으로 하는 것이어서 단지 근로자 보호를 위한 방법론적인 차이가 있는 것에 불과한 것이다. 따라서, 노동조합법상의 근로자에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서도 그 계약이 민법상의 고용계약이든 또는 도급계약이든 그 계약의 형식에 관계없이 그 실질에 있어 근로자가 임금 등을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 할 것이고…… 근로자인지 여부를 판단하는 기준인 사용종속성이나 근로의 대상성에 관한 판단에 있어서 근로기준법과 노동조합법 사이에 어떤 차이가 있다고 할 수 없"다고 한다.

31) 예컨대 레미콘운송차주의 노조법상 근로자개념에 관한 두 판결(대법원 2006. 5. 11. 선고 2005다20910 판결과 대법원 2006. 6. 30. 선고 2004두4888 판결)에서 대법원은 근기법상 근로자개념에 관한 판단기준을 제시한 1994년 대법원 판결을 인용하는 대신, 골프장경기보조원의 노조법상 근로자성을 인정한 대법원 1993. 5. 25. 선고 90누1731 판결을 인용하면서, "노동조합및노동관계조정법(이하 '노동조합법'이라고 한다) 제2조 제1호는 "근로자라 함은 직업의 종류를 불문하고 임금·급료 기타 이에 준하는 수입에 의하여 생활하는 자를 말한다" 고 규정하고 있다. 여기에서 근로자란 타인과의 사용종속관계하에서 노무에 종사하고 그 대가로 임금 등을 받아 생활하는 자를 말한다. 또 그 사용종속관계의 존재 여부는 당해 노무공급계약의 형태가 고용, 도급, 위임, 무명계약 등 어느 경우이든 상관없이 사용자와 노무제공자 사이에 지휘·

www.kci.go.kr

제된 사건에서는 1994년 대법원 판결이나 2006년 대법원 판결의 설시내용을 그대로 인용하고 있는 것과 달리, 노조법상 근로자성을 판단한 판결에서는 1994년 판결을 인용하지 않고 있고,[32] 노조법에서의 독자적인 판단기준을 명시적으로 제시하지 않은 것은[33] 대법원이 노조법상 근로자개념이 문제된 사건에서는 근기법상 근로자개념 판단기준을 직접 적용하는 것을 의식적으로 회피하고 있다는 것을 시사한다.[34] 바꾸어 말하면, 노조법상 근로자개념을 확정하는 핵심적 요소인 사용종속관계에 관한 판단기준이 근기법상 근로자개념과 다르게 적용될 여지를 대법원이 배제하지 않고 있다는 것이다.[35]

학설은 근기법상 근로자개념과 노조법상 근로자개념은 차이가 있다는 점에 일치하고 있다.[36] 그렇지만 다수의 학설에서는 실업자를 제외하고

감독관계의 여부, 보수의 노무대가성 여부, 노무의 성질과 내용 등 그 노무의 실질관계에 의하여 결정된다"고 판단하고 있을 뿐이다.

32) 이 판결은 근기법상 근로자성에 관한 2006년 대법원 판결(2006. 12. 7. 선고)이 선고되기 전에 나온 판결이다.

33) 특히 골프장경기보조원의 근기법상 근로자개념에 관한 대법원 1996. 7. 30. 선고 95누13432 판결에서도 노조법상의 근로자개념이 문제된 대법원 1993. 5. 25. 선고 90누1731 판결은 인용하고 있지 않은 점에서도 양자의 판단기준을 달리 적용하겠다는 대법원의 입장을 유추할 수 있다.

34) 또한 학습지교사의 노조법상 근로자성이 문제된 사건(대법원 2005. 11. 24. 선고 2005다39136 판결)에서도 학습지교사의 노조법상 근로자성을 결론적으로 부인하기는 하였으나, 학습지교사의 근기법상 근로자개념이 문제된 사건에서 명시적으로 1994년 판결을 인용하고 있는 것과 달리 1994년 판결을 인용하지 않은 점이 주목된다.

35) 대법원은 노조법상 근로자개념에 관하여 적극적인 판단기준을 제시하지 않고 있기 때문에 노조법상 근로자개념에 관한 판단기준이 근기법의 그것과 상이할지 동일할지는 향후의 판례형성을 기다릴 필요가 있을 것이다. 서울여성노동조합사건(대법원 2004. 2. 27. 선고 2001두8568 판결)에서 대법원은 법의 목적의 차이에 의해 특정 사용자에게 고용되어 현실적인 취업관계에 있지 않은 일시적 실업자 또는 구직중인 자에 대해서도 노조법상 근로자개념을 확장하고 있으나, "특정 사용자에게 고용되어 현실적인 취업관계에 있는 자"가 근기법상 근로자개념에 해당하는 자에 한정되는지에 대한 판단을 한 것은 아니다.

36) 각 학설의 내용에 대한 소개는 박수근, "레미콘운송기사와 경기보조원의 근로자성에 관한 검토", 『노동법학』 제14호, 2002, 35-36쪽.

www.kci.go.kr

는 구체적으로 양자가 어떻게 차이가 있는지를 설명하고 있지 않다. 오히려 구직 중인 자 내지 실직자를 제외하고, 현실적인 취업관계에 있는 자에 대해서는 사용종속관계의 판단기준을 동일하게 파악하고 있는 것처럼 보인다.[37]

이에 대하여 양자의 구별을 전제로 하여, 인적 종속성과 대비되는 경제적 종속성을 강조하면서 고용형태의 다양화에 대응하는 근로자성 판단의 틀을 질적으로 변화시켜야 한다는 전제하에서 일반적으로 근기법상 근로자 개념에 비하여 노조법상 근로자의 개념이 넓을 수 있다는 점을 지적하는 견해,[38] 노조법과 근기법상의 근로자개념은 서로 중첩되는 부분이 많지만 목적과 필요성이 다르므로, 사용종속성의 구성요소와 판단방법도 다르다는 견해[39]도 있다.

3) 근기법과 노조법에서의 사용종속성

근기법상 근로자와 노조법상 근로자의 사용종속관계를 양적·질적으로 동일하게 파악하는 입장에는 동의하기 어렵다.[40] 근기법과 노조법은 입법목적에서 차이가 있을 뿐만 아니라 그 목적을 실현하는 방법에 있어서

---

37) 각 교과서의 근로자 개념에 관한 설명을 보면, 공통적으로 노조법상 근로자 개념을 설명하면서 근기법상 근로자개념에 관한 판례를 제시하고 있어 실제로는 오히려 양자를 엄격하게 구별하고 있지 않은 것은 아닌가 하는 인상을 받게 된다. 이는 학설이 최소한 사용종속관계의 판단, 즉 실업자에 대한 것이 아니라 "현실적으로 취업하고 있는 자"의 사용종속관계에 관하여는 근기법과 노조법이 동일하다는 것을 전제로 하고 있기 때문은 아닌가 추측된다. 다만 최소한 취업관계에 관한 한, 명시적으로 양자의 개념이 동일하다는 것을 지적하면서 노동법상의 근로자개념이 통일적으로 파악되어야 한다는 견해가 없는 것은 아니다(이병태, "노동법상 노동자의 개념", 법률신문 제1217호, 1977.8.).

38) 최영호, "계약근로형 노무공급자의 근로자성", 『노동법연구』 제13호, 2002, 145쪽.

39) 김재훈, "특수형태근로 종사자에 대한 법적 보호방안", 『노동법연구』 제13호, 2002, 159쪽; 박수근, "특수고용형태의 근로자성" 한국노동법학회 자료집, 2001.12., 97-98쪽.

40) 김형배, 『노동법』, 박영사, 2006, 1090쪽에서도 노조법상 근로자를 "근로기준법상의 사용종속관계, 다시 말해서 엄격한 인격적 종속관계로 해석할 아무런 근거가 없다"고 지적한 바 있다.

www.kci.go.kr

도 본질적인 차이가 있기 때문이다.

위의 하급심에서는 종속노동의 대가로 생활을 영위하는 자의 보호를 목적으로 하는 점에서는 차이가 없고 단지 근로자 보호를 위한 방법론적인 차이가 있는 것에 불과하다고 한다. 그러나 설령 이 입장과 같이 양 법 사이에 목적의 동일성을 인정한다고 하더라도, 그 목적 달성의 수단으로서 개별적인 근로계약에 국가가 벌칙의 적용을 전제로 하여 강행적으로 개입하여 계약의 내용을 직접 수정·보완하는 체제를 취하고 있는 근기법이 대상으로 하는 개별적 근로관계와, 계약형성에 관한 국가의 직접적 개입 없이 노사의 자치로 집단적 교섭을 통하여 계약내용을 자발적으로 형성하는 체제를 취하고 있는 노조법이 대상으로 하는 집단적 노사관계는 질적으로 차이가 있다고 보아야 한다.[41]

이러한 두 법 사이의 목적, 수단의 차이는 그 인적 적용대상을 판단함에 있어서도 반영되어야 한다. 근기법에서는 사적 자치에서 야기된 불합리한 폐해를 국가에 의해 강행적으로 회복시키는 것을 정당화할 정도의 근로자의 종속성을 요하지만 노조법에서는 집단적 사적 자치에 의하여 노사당사자가 개별적 사적 자치의 불합리한 결과를 스스로 교정할 수 있는 능력을 가지고 있기 때문에 인적 적용대상을 반드시 근기법과 동일한 범위로 제한할 필요가 없다. 특히 단체교섭은 기본적으로 노동력의 경제

41) 근기법은 당사자간의 계약내용에 국가가 후견적인 입장에서 직접 개입하여 계약내용을 시정하고 최저기준에 미달하는 계약에 대해서는 벌칙에 의해 그 이행을 담보하기 때문에 사적 자치에 대한 국가의 직접적 개입의 정당화가 요청된다. 즉 사적 자치에서 야기된 불합리한 폐해를 국가에 의해 강행적으로 회복시키는 것을 정당화할 정도의 근로자의 종속성이 전제로 되지 않으면 안 된다.

이에 대하여 노조법은 당사자간의 계약형성에 있어서의 교섭력의 불균형을 단체교섭 등 당사자 사이의 자치적인 집단적 교섭을 통하여 시정하는 것을 목적으로 하고 있다. 개별적 사적 자치의 불합리한 결과를 단체교섭에 의한 노동력의 거래조건에 관한 집단적 교섭, 쟁의행위에 의한 노동력의 집단적 제공거부 등을 통하여 교정하여 집단적 사적 자치를 도모하는 것을 목적으로 한다. 집단적 교섭에 의해 교섭력의 불균형을 시정할 수 있기 때문이다. 그렇기 때문에 국가의 개입을 당연한 전제로 하는 근기법과는 반대로 노조법에서는 국가의 개입이 오히려 부정적인 평가를 받는 것이다.

www.kci.go.kr

적 거래조건에 초점을 두어 이루어지고 있고 노조법의 체제나 판례의 태도 역시 이러한 대상에 국한하는 경향을 보이고 있다. 그렇다면 노조법상의 사용종속관계는 경제적 종속관계를 중심으로 이해하는 것이 타당하다.

그런데, 노조법상의 사용종속관계에 인적 종속관계가 전혀 배제되어 있다고 보기는 힘들다. 전체 법질서에서 볼 때 공정거래법에서 금지하고 있는 담합행위와 같은 집단적 행위가 노조법에서는 특별히 허용되고 있고 헌법이 이를 보장하고 있는 것은 노조법 등이 사용자에 비하여 근로자가 처한 열악한 경제적 지위만을 고려한 것이 아니라 경제적으로 취약한 지위에 있는 전형적인 자영업자 내지 사업자와 달리 사회적으로 사용자에 대해 종속되어 있다는 규범적 가치판단을 전제로 하고 있기 때문이다. 따라서 노조법상 근로자에 대해서도 일정한 정도의 인적 종속성이 요구된다고 하는 것이 타당하다.

문제는 인적 종속성의 정도와 수준이 근기법상의 그것과 동일한가 하는 것이다. 노조법에서 전제로 하는 인적 종속성이 근기법에서 대상으로 하는 인적 종속성과 질적으로 차이가 있다고 하기는 어려울 것이다. 즉 현실적인 취업관계 하에 있는 자가 노무제공의 내용과 방법 등에 대하여 사용자에 의한 지휘·통제를 받는다는 점에서는 양자는 동일하다. 다만 앞에서 본 바와 같이 노조법의 목적과 체계, 전체적인 메카니즘을 고려하면 노조법상의 근로자성 판단에서 차지하는 인적 종속성은 판례가 근기법상 근로자에 대해 요구하는 요소의 모두를 엄격하게 충족하는 경우에만 인정되어야 할 필요는 없고 그 중 일부 요소가 결여되는 경우 또는 사용자의 지휘·통제권이 추상적·개괄적으로 행사되는 경우와 같이 양적인 측면에서는 근기법상의 요건을 갖추지 못하는 경우까지 포섭하는 것으로 이해하는 것이 합리적이다. 요컨대 노조법상 근로자개념은 근기법상 근로자개념에 비하면 경제적 종속성의 측면에서는 양적·질적으로 동일하지만, 인적 종속성의 측면에서는 질적으로는 동일하나 양적으로는 차이가 있다고 해석하는 것이 타당하다.[42]

---

42) 따라서 노조법상의 근로자가 근기법상의 근로자보다 넓은 개념이라는 견해(임종률, 『노동법(11판)』, 박영사, 2013, 36쪽)는 전적으로 타당하다.

www.kci.go.kr

이런 관점에서 본다면 현행법의 해석에 의하더라도 유형 1에 해당하는 노무제공자에 대해서는 최소한 노조법상 근로자성을 충분히 인정할 여지가 있다고 생각된다.

4) 정리

이상을 요약하면, 유형 1, 즉 노무제공자가 기업의 업무를 도급이나 위임받는 형태로 노무를 제공하는 경우에 판례에 따르면 2006년 이전에는 근기법상의 보호를 부정하는 경향에 있었으나, 2006년 근기법상 근로자성 판단기준의 변화 이후 일부 긍정하는 방향으로 변화를 보이고 있다. 집단적 노동관계와 관련하여서는 판례는 근기법의 판단기준을 그대로 적용하는 것은 아니지만, 여전히 사용종속성을 요구하고 있고, 사실관계에 따라서 노조법상 근로자성이 인정되는 경우와 부정되는 경우가 병존하고 있는 상태라고 요약할 수 있다. 결국 판례에 따르면 노무제공자가 노무도급형태로 노무를 제공하는 경우에는 사용자와의 근로계약관계가 인정되어 노동법의 전면적인 적용대상이 되거나, 근로계약관계가 부정되어 노동법의 적용대상에서 완전히 배제되어버리는 결과가 된다.

유형 1과 같은 이른바 특수형태고용종사자의 특징을[43] 감안할 때, 노무제공상대방은 개인인 노무도급제공자 보다 교섭력이 우월한 경우가 대부분이다. 그 결과, 노무제공자는 보수나 수수료 단가의 덤핑, 단가의 일방적 인하나 체불, 계약의 중도해지나 갱신거부 등의 불이익을 받을 수 밖에 없다. 즉 유형 1의 노무제공자는 노무제공상대방에 대해 인적 종속성은 부분적으로만 인정된다고 하여도 경제적으로는 사실상 완전히 종속되고 있다. 그럼에도 불구하고 현행법제도 하에서는 전면보호 아니면 전면부정이라는 양자택일적인 선택 밖에는 법적으로 불가능하여 노무제공

43) 근로계약이 아니라 도급이나 위임 또는 준위임계약 등을 체결하거나 아무런 계약 없이 노무를 제공하는 점, 노무제공 상대방의 사업목적을 위하여 업무를 수급받고 있는 점, 보수가 성과급으로 지급되는 점, 계약기간이 정해져 있는 점, 시간적·장소적 제약이 상대적으로 약한 점, 업무수행과 관련하여 일정한 재량권이 인정되는 점, 노무제공상대방에게 전속적으로 노무를 제공하여 경제적으로 의존하는 점 등을 들 수 있다.

www.kci.go.kr

의 실태에 부합하지도 않고 법리적으로도 합리성을 결하고 있다고 평가할 수 있다.

이러한 유형의 노무제공자에 대해 '근로자유사한 자' 내지 '종속적 노무제공자'라는 제3의 범주를 창설하고 사용종속성의 정도에 따라 노동보호법의 일부조항을 적용하면서, 교섭력의 불균형을 시정하기 위한 교섭제도의 틀을 갖추도록 할 것인지, 전면적으로 근로자성을 인정할 것인지, 아니면 제3의 다른 방법을 모색할 것인지를 검토할 필요가 있다.

2. 사용자개념에 대한 판례의 입장: 유형 2에 대한 검토

1) 문제상황

유형 2는 기업 업무를 근로자파견을 통해 파견기업의 파견근로자를 이용하여 수행하도록 하거나 업무도급을 통해 하청기업의 근로자로 하여금 수행하도록 하는 유형이다. 여기에는 두 가지 문제가 혼재되어 있다. 첫째, 삼면적 고용관계, 즉 고용과 사용이 분리되는 경우에 사용자개념을 어떻게 획정할 것인지가 문제된다. 여기에서 근로자개념은 문제되지 않는다. 파견근로자든 하청기업의 근로자든 근로자성 자체는 부정될 여지가 없기 때문이다. 쟁점으로 되는 것은 파견근로자나 하청기업의 근로자에 대해 누가 사용자로서의 지위를 가지고 책임을 부담하는가이다. 유형 1은 근로자 개념을 어떻게 포착하는지가 핵심적인 것이고, 여기에 따라 노무제공의 상대방의 지위는 자연스럽게 결정된다. 반면 유형 2는 사용자개념을 어떤 식으로 확정하여 누가 사용자책임을 부담하는지만 결정하면 근로자성은 특별히 문제되지 않고 그 사용자에 대해서 노동법상의 책임과 의무를 물을 수 있게 된다. 이와 관련한 사용자책임 내지 개념은 이른바 불법파견 내지 위장도급의 문제로서 논의되어 왔다.

둘째, 불법파견, 즉 위장도급이 아니라 진정도급인 경우에 원청인 회사에 대해 하청기업의 근로자는 민법상 도급인과 수급인의 이행보조자 관계에 지나지 않는데, 그럼에도 불구하고 원청기업은 하청근로자에 대해 노동법적인 관점에서 책임을 부담하여야 하는가, 부담하여야 한다면 어떠한 책임을 부담하여야 하는지도 문제된다. 노무도급이 원청기업의 구내에

www.kci.go.kr

서 이루어지는 경우, 즉 사내하청의 경우가 이러한 문제의 핵심이 되고 있다. 현행법상 진정도급에 대한 근로자 보호와 관련하여서는 노동법, 민법, 하도급법에 의한 규율이 이루어지고 있다.[44] 그러나 이러한 규정은 도급인인 원청의 경제적 우월성을 전제로 하여 정책적으로 책임을 확장한 것에 지나지 않고 원청근로자와 하청근로자 사이의 법률관계를 전제로 하고 있는 것은 아니기 때문에[45] 하청근로자 보호에는 한계가 있다.

이를 배경으로 하여, 고용노동부는 노사정위원회, 노동시장선진화위원회에서 제시한 공익위원안을 중심으로 한 2011.7.18. '사내하도급 근로자의 근로조건 보호 가이드라인'을 제정·운용하고 있으나,[46] 이를 제외하고는 이른바 진정도급에서 원청 사업주와 사내하청 근로자의 관계를 노동법적 관점에서 종합적으로 규율하는 제도는 아직 존재하지 않는다.[47]

2) 판례의 입장

첫 번째 문제, 즉 이른바 위장도급이 문제되는 상황에서 판례는 두 단

---

44) 노동법적인 규율로는 임금 지급 및 산업안전과 관련하여 원사업주가 일정한 부담을 지도록 하고 있고(근기법 제44조, 제44조의2, 제44조의3, 제90조; 최저임금법 제6조 제7항 내지 제9항; 산업안전보건법 제29조; 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 제9조; 고용보험법 제15조; 건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 제10조 등), 민법에서는 수급인의 담보책임 및 보수의 지급시기(민법 제664조), 목적부동산에 대한 저당권설정청구권(민법 제666조) 등 수급인의 보호를 위한 규정을 두고 있다. 그 밖에 하도급거래 공정화에 관한 법률에서 원사업자의 부당한 행위를 억제하고 수급사업자의 열위적 지위를 보완하기 위한 각종 규정을 두고 있다.

45) 이철수, "사내하도급의 실태와 법적 대응", 『노동법의 이론과 실천, 신인령선생님정년기념논문집』, 박영사, 2008, 76-80쪽.

46) 여기에서는 사내하도급근로자의 임금 등 근로조건 보장, 산업안전보건조치, 수급사업주 교체시 근로자의 고용승계, 사내하도급근로자의 근로삼권 보장, 차별적 처우 금지 등을 규정하고 있다. 이 가이드라인은 말 그대로 '가이드라인', 즉 일종의 '권고'로서 법적으로는 행정지도에 불과하기 때문에 근로감독관을 통한 사실상의 구속력은 가질 수 있으나 법적인 구속력은 없다.

47) 새 정부 출범 직후 대통령공약에 따라 새누리당은 2012년 5월 19대 국회 1호 법안으로 "사내하도급근로자보호등에관한법률"안을 발의하였으나, 위장도급과의 구별이 명확하지 않은 상태에서 위장도급에 대한 사실상 면죄부를 준다는 비판에 직면하여 통과되지는 않았다.

www.kci.go.kr

계의 접근방식을 취하고 있다. 먼저, 사용사업주 또는 원청기업과 파견근로자 내지 하청근로자 사이에 묵시적 근로계약관계가 존재하는지 여부를 판단한다. 묵시적 근로계약관계가 부정되면 다음으로 사용기업과 하청근로자 사이에 진정한 근로자파견관계가 존재하는지 여부 내지는 도급관계인지를 판단한다. 근로자파견관계가 존재하기 위해서는 근로자파견법의 요건에 따른 파견이 적법하게 이루어져야 하고, 그것이 인정되면 근로자파견법에 기한 사용사업주로서의 책임만 부담하면 되고 그 밖의 파견근로자의 사용자책임은 파견기업이 부담한다. 진정도급관계인 경우에는 전적으로 하청기업이 사용자책임을 부담하게 된다.

그런데, 외관상 도급의 형태를 취하고 있으나 실질은 하청근로자가 도급인인 원청기업과의 사이에 사용관계 하에 있는 것으로 인정되는 경우, 누가 어떠한 책임을 져야 하는지가 문제된다. 이러한 문제에 대해 법원은 이른바 사내하도급 삼부작 판결을[48] 전개하면서 물음에 일부 답하고 있다.

첫째, 묵시적 근로관계의 성립과 관련하여 현대미포조선 판결은[49] "원고용주에게 고용되어 제3자의 사업장에서 제3자의 업무에 종사하는 자를 제3자의 근로자라고 할 수 있으려면, 원고용주는 사업주로서의 독자성이 없거나 독립성을 결하여 제3자의 노무대행기관과 동일시할 수 있는 등 그 존재가 형식적, 명목적인 것에 지나지 아니하고, 사실상 당해 피고용인은 제3자와 종속적인 관계에 있으며, 실질적으로 임금을 지급하는 자도 제3자이고, 또 근로제공의 상대방도 제3자이어서 당해 피고용인과 제3자 간에 묵시적 근로계약관계가 성립되어 있다고

48) 이는 사내하도급관계에서 발생한 노동분쟁을 다룬 세 개의 대법원 판결, 즉 대법원 2008. 7. 10. 선고 2005다75088 판결('현대미포조선 판결'), 대법원 2008. 9. 18. 선고 2007두22320 전원합의체 판결('예스코 판결') 및 대법원 2010. 3. 25. 선고 2007두8881 판결('현대중공업 판결')이 상호 보충적인 의미를 가지고 있다는 의미에서 사용되고 있다. 이들 판결에 대한 상세한 내용과 의미에 대해서는 강성태, "사내하도급 삼부작 판결의 의의", 『노동법학』 제35호, 한국노동법학회, 2010.9. 1쪽 이하 참조. 예스코 판결은 이 글의 논지와 직접 관련성이 없기 때문에 내용의 소개는 생략한다.

49) 대법원 2008. 7. 10. 선고 2005다75088 판결.

www.kci.go.kr

평가될 수 있어야 한다"는 종래 확립된 판지를 인용하면서, 사내하청기업 근로자와 원청회사 사이의 묵시적 근로관계의 성립을 인정하고 있다.

둘째, 묵시적 근로계약관계가 인정되지 않을 경우, 사용기업, 즉 원청은 하청기업 근로자에게 어떠한 책임을 부담할 수 있는가. 판례는 원청회사의 지배개입의 부당노동행위가 다투어진 현대중공업사건에서[50] "근로자의 기본적인 노동조건 등에 관하여 그 근로자를 고용한 사업주로서의 권한과 책임을 일정 부분 담당하고 있다고 볼 정도로 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자가, 노동조합을 조직 또는 운영하는 것을 지배하거나 이에 개입하는 등으로 법 제81조 제4호 소정의 행위를 하였다면, 그 시정을 명하는 구제명령을 이행하여야 할 사용자에 해당한다"고 판시하고 있다.[51]

3) 의의와 한계

현대중공업판결은 노조법상 사용자개념을 확대하면서, 원청기업의 사내하청근로자에 대한 사용자책임의 일부를 인정한 점에서 적극적으로 평가하지 않을 수 없다. 종래 형식적인 근로계약을 중심으로 사용자개념을 파악하던 소극적인 입장에서 형식적인 근로계약을 넘어서 사용자로서의 지위와 권한을 인정하는 적극적인 입장으로 전환하였다고 볼 수 있기 때문이다.

이러한 의의에도 불구하고, 이 판결은 과제도 많이 제기하고 있다. 첫째, 현대중공업판결은 노조법상 사용자개념에 관한 판결이라기보다는 지배개입의 부당노동행위 주체로서의 사용자개념에 관한 판결이기 때문에, 다른 사건, 예컨대 단체교섭의 상대방으로서의 사용자, 단체협약의 주체

---

50) 대법원 2010. 3. 25. 선고 2007두8881 판결.

51) 강성태 교수는 이 판결의 의의로서, 기존의 판례와 달리 근기법상 사용자와 노조법상 사용자가 다를 수 있음을 인정한 점에서 의의가 있다고 하고 있으나(앞의 논문, 26쪽), 앞에서 본 바와 같이 기존의 판례는 처음부터 근기법상 사용종속관계와 노조법상 사용종속관계를 사실상 달리 파악하고 있다고 이해하는 것이 타당할 것이다.

www.kci.go.kr

로서의 사용자, 쟁의행위의 상대방으로서의 사용자에 대해서도 동일한 판지를 유지할 수 있을 것인지 여부는 현 단계에서는 명확하지 않다.[52] 그러나 이는 아래에서 살펴볼 유형 3과 유형 4에 대한 판례의 입장을 예단할 수 있는 기준이 될 수도 있고 동시에 각종 입법론에서 제시되는 사용자개념을 구성한다는 의미에서 적극적인 검토가 필요하다.

둘째, 이 판결에서는 원청기업의 사용자성을 일부 인정하고 있는데, 그 근거를 "근로자의 기본적인 노동조건 등에 관하여 그 근로자를 고용한 사업주로서의 권한과 책임을 일정 부분 담당하고 있다고 볼 정도로 실질적이고 구체적으로 지배·결정"하는 데에서 찾고 있다. 즉, 판결은 원청기업의 지휘명령권의 근거를 근로조건을 부분적으로 결정할 수 있는 지위에서 구하고 있는 것이다. 그 의미가 근로조건을 "지배·결정"하는 지위에 있다는 점에서 원청에 대해 근로계약상의 사용자와 유사한 사용자성을 인정한 것인지 아니면 근로계약과 무관하게 근로조건을 지배·결정하고 있다는 사실에서 지휘명령권을 도출하고 있는지가 명확하지 않다. 요컨대 사용자의 하청근로자에 대한 지휘명령권의 근거가 '근로계약관계'를 전제로 한 권한인지 아니면 '근로계약 없는 근로관계'에서 도출되는 권한인지가 명확하지 않다. 후자라면, 이 판결의 의미는 사용자개념의 실질적인 확장으로 이어질 것이고, 전자라면 근로계약과 최소한 유사한 관계를 인정할 수 있는 경우에만 사용자개념을 확대할 수 있기 때문에 그 범위는 축소될 것이다.

셋째, 이 판결은 원청이 사업주로서의 권한과 책임을 "일정 부분" 담당하고 있기 때문에 '부분적' 사용자성을 인정한 것이라고 볼 수 있는데, 그렇다면 원청기업이 부담하는 책임의 범위가 어디까지 미치는지가 명확하지 않다. 하청근로자의 원래 고용주인 하청기업의 사용자로서의 책임

52) 다만 하급심 중에는 "비록 근로계약관계의 당사자가 아니라고 하더라도 단체교섭의 대상이 되는 근로조건에 관하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있으면 단체교섭의 당사자로서의 사용자에 해당한다"고 판시한 사례(대전지법 2011.10.6.자 2011카합782 결정)가 나타나고 있는 점, 이 판결의 모델이 되었다고 할 수 있는 일본의 朝日放送 사건 최고재판소 판결(最三小判 1995.2.28.)은 단체교섭거부와 관련된 사건이었다는 점에서 최소한 단체교섭의 상대방으로서의 사용자개념에는 적용될 것으로 보인다.

www.kci.go.kr

전체를 '공동' 내지 '중첩적으로' 부담한다는 의미인지 아니면 원청기업이 행사한 지휘명령권의 범위 내에서 '부분적'으로 부담한다는 의미인지가 명확하지 않은 것이다. 만약 후자라면, 그 범위는 어떻게 획정되는 것인지도 문제된다.

3. 사용자개념 확대와 유형 3에 대한 검토

1) 문제의 소재

지주회사와 모회사와 같이 자회사의 사업내용에 대한 지배가 법적으로 전제되어 있는 경우(독점규제 및 공정거래에 관한 법률. 이하 '공정거래법' 제2조 1의2호 및 1의3호; 상법 제342조의2 제1항 참조), 자회사의 근로자가 지주회사나 모회사를 상대로 사용자책임을 물을 수 있는지가 문제된다. 바꾸어 말하면 자회사 근로자에 대해 지주회사나 모회사의 사용자로서의 지위와 권한을 인정할 수 있는가 하는 것이다.

사내하청이나 파견근로에서는 하청근로자나 파견근로자는 원청기업이나 사용기업에 대해 직접적으로 노무를 제공하고, 또 원청기업이나 사용기업은 하청근로자나 파견근로자에 대해 노무수행을 둘러싼 지휘명령권을 실질적으로 또는 법적으로 인정받고 있다. 이 점에서 원청기업 등은 하청근로자 등에 대해 노무제공이나 근로조건의 결정과 관련하여 직접적인 지배관계를 인정받을 여지가 있다. 현대중공업판결은 이 점에 착안한 것이라고 할 수 있다. 따라서 이러한 직접적인 지배관계를 출발점으로 하여 원청기업이나 사용기업에 대해 사용자로서의 책임을 물을 가능성이 존재하게 된다(유형 2).

이에 대하여 지주회사나 모회사는 자회사 근로자의 노무를 직접 수령하지 않을 뿐만 아니라 지주회사나 모회사의 지배력은 원칙적으로 자회사 자체에 대해 이루어지는 것이고, 자회사의 근로자를 대상으로 이루어지는 것은 아니다. 즉 지주회사나 모회사는 자회사의 경영방침이나 인사정책 등에 대해 제도적으로 관여할 수 있는 지위에 있지만, 그러한 지배는 자회사를 통하여 간접적으로 이루어지고 구체적인 인사정책이나 노사관계정책은 자회사에 의해 구체화된다. 요컨대 모회사나 지주회사는 지배

www.kci.go.kr

주주로서의 지위와 함께 근로계약당사자가 아니라는 점을 이용하여 자회사의 근로조건을 실질적으로 결정할 수 있으면서도, 노동법상의 사용자책임을 회피할 수 있다. 이러한 상황에서 자회사 근로자는 지주회사나 모회사에 대해 사용자성을 주장할 수 있는가 하는 것이 문제되는 것이다.

2) 해석에 의한 문제해결의 시도와 한계

이에 대해 법원에서 다투어진 사례는 아직은 존재하지 않는 것으로 보인다. 다만 학설상으로, 자본・임원구성・영업내용 등의 면에서 특정 기업을 완전히 지배하고 있는 기업에 대해서는 근로조건 등에 대해 실질적 영향력 내지 지배력을 행사하고 있다고 하여 사용자성을 인정하는 견해,[53] 모회사가 자회사의 경영을 지배하면서 자회사 근로자의 임금・인사 등 근로조건을 실질적・구체적으로 지배・결정한 경우에 모회사도 고용주인 자회사와 함께 부당노동행위 주체로서의 사용자 지위를 가진다고 보는 견해,[54] 나아가 사용자를 "지배적 영향력을 행사하고 있는 자"로 정의하고 기업집단 자체를 하나의 '사업'으로 보는 견해[55] 등 모회사나 지주회사의 사용자성(최소한 부당노동행위와의 관련에서)을 인정하는 것이 일반적이다.

마지막 견해, 즉 주식보유를 통한 지배력을 자회사 근로자의 근로조건에 대한 지배력과 사실상 동일시하고 있는 견해를[56] 제외하고는 전체적으로 현대중공업판결과 유사한 기준을 적용하여 모회사의 사용자성을 긍정하고 있는 것으로 보인다.

그런데, 현실적으로 현대중공업판결의 판지를 원용하여, 모회사나 지주회사의 사용자성을 긍정하는 데에는 상당한 어려움이 수반될 것으로 보인다. 우선, 모회사나 지주회사가 "근로자의 기본적인 노동조건 등에 관

53) 김유성, 『노동법 II』, 법문사, 1999, 131-132쪽.
54) 임종률, 앞의 책, 266쪽; 김형배, 『노동법(22판)』, 박영사, 2013, 1082쪽.
55) 박제성・박지순・박은정, 『기업집단과 노동법』, 한국노동연구원, 2007, 240-245쪽.
56) 주식소유관계로부터 바로 지주회사의 자회사에 대한 노동관계에서의 지배력을 이끌어내는 것은 현실적으로나 규범적으로 용이하지 않을 것으로 판단된다.

www.kci.go.kr

하여 그 근로자를 고용한 사업주로서의 권한과 책임을 일정 부분 담당하고 있다고 볼 정도로 실질적이고 구체적으로 지배·결정"하고 있다는 것을 입증하기는 상당히 어려울 것이다. 물론 지주회사 등이 자회사의 노무관리상황에 대해 구체적인 조치를 스스로 하는 경우에는 지배력의 행사를 입증하기 용이할 수 있지만,[57] 기획이나 추상적인 지시에 머무르고 구체적인 결정과 집행을 자회사가 한다면, 이러한 요건에 부합하는지가 문제될 수 있는 것이다. 다만, 지주회사 등의 추상적인 지시라고 하더라도 자회사에 대해서는 실질적인 강제력을 가지기 때문에 구체적 지배력의 행사로 볼 여지가 없는 것은 아니다. 이를 규명하기 위해서는 모회사나 지주회사가 주주권의 행사, 자금의 배분, 거래관계 등을 통해 어느 정도 자회사의 노무정책에 관여할 수 있는지 여부, 관여의 정도, 과정에 대한 입증이 필요하나, 이것 역시 용이할 것으로 보이지는 않는다. 이 점에서 현대중공업판결의 판지는 사용자개념을 확대한 의미도 있지만, 다른 한편에서는 유형 3과 같은 사건에서는 족쇄로 기능한다고 할 수 있다.[58]

현대중공업판결 판지에 의한 사용자개념 확대를 유형 3에 유추하기 가장 어려운 지점은 노조법 전체 틀과의 정합성이다. 사용자가 근로계약상의 사용자라면 단체교섭을 통하여 단체협약을 체결하거나 쟁의행위를 하는 것이 제도적으로 갖추어져 있다. 그러나 모회사나 지주회사의 경우 실질적·구체적 지배·결정권한을 인정하여 사용자개념을 확대한다고 하더라도 자회사 근로자와 근로계약관계 자체가 존재하고 있지 않기 때문에, 모회사나 지주회사에 대해 단체교섭의 상대방으로서의 지위를 인정하고 이들과 단체협약을 체결한다고 하더라도 모회사나 지주회사가 체결한 단체협약이 자회사 근로자가 (모회사나 지주회사가 체결한 근로계약이 아닌) 자회사와 체결한 근로계약에 규범적 효력을 미치도록 하는 것이 현행 노조법의 틀 속에서 가능한가라는 근본적인 의문이 제기될 수 있는

57) 이 경우가 앞에서 살펴 본 학설이 상정하고 있는 사례로 보인다.

58) 실제로 일본에서 朝日 送사건 최고재판소 판결이 나온 이후 유형 3에 해당하는 사건에 대한 하급심 판결과 노동위원회 명령은 朝日 送사건 기준을 적용하면서도, 그 기준을 갖추고 있는지 여부에 대해서 매우 엄격하게 판단하는 경향이 있다고 한다(木南直之, "勞働組合法上の使用者概念と團交事項", 日本勞動法學會誌 119호, 2012, 66쪽).

www.kci.go.kr

것이다.[59]

요컨대 현대중공업 판지에서 제시한 기준으로는 모회사나 지주회사의 사용자성을 직접적으로 인정하는 데 어려움이 있고, 이를 위해서는 추가적인 논리구성이 필요하다고 본다.

4. 사용자개념 확대와 유형 4에 대한 검토

1) 문제의 상황

합병이나 영업양도 등 기업매수가 예정되어 있는 상황에서 합병예정회사나 양수예정회사가 상대방회사에 대해 인원삭감, 임금 인하 등 선제적인 구조조정을 하는 조건으로 계약을 체결하겠다는 압력을 가하는 상황은 용이하게 상정할 수 있다. 이 때 기업변동의 대상이 되는 기업의 근로자가 합병예정회사 등을 상대로 사용자로서 단체교섭 등을 요구할 수 있는지가 문제될 수 있다.

주식보유를 통하여 자회사에 대한 법적·간접적인 지배력을 확보하고 있는 지주회사나 모회사의 경우(유형 3)와 달리 이 경우에는 양도예정회

---

59) 이 문제를 해결하기 위해 단체교섭권보장의 의미를 독자적으로 구성하여, 적절한 설명, 설득의 기회를 부여한다는 데 단체교섭보장의 취지가 있다는 전제하에, 모회사나 지주회사에 대한 단체교섭은 근로조건의 결정에 주안점이 있는 것이 아니라 단체교섭 과정에서 사용자로부터 적절한 설명을 듣고 노조의 의견을 반영시키는 설명과 납득의 절차로 구성하고, 모회사나 지주회사에 대해 '성실교섭의무'를 부과한다는 점에서 의의를 찾는 견해(道幸哲也, "親會社の團交應諾義務一なんのための團交權", 季刊 働法 216호, 2007년 봄, 176-177쪽)가 있다. 유사한 취지로 木南 之, 앞의 논문, 67쪽 이하 참조.
이러한 견해는 단체교섭을 단체협약 체결을 위한 수단으로 보지 않고, 노사간의 커뮤니케이션 확보를 위한 권리로서 파악하여 지주회사나 모회사와 자회사 근로자 사이의 노사 간의 정보교환, 협의 그 자체에 의미가 있다고 파악하는 것이다. 이러한 입장에 따르면 모회사나 지배회사의 단체교섭의무의 범위는 정보제공의무와 설명의무에 국한된다고 한다(道幸哲也, 앞의 논문, 177쪽). 일본과 달리 단체교섭의 주체와 단체협약의 주체, 나아가 쟁의행위의 주체를 일치시키고 있는 우리나라의 집단적 노사관계 운용 상황에서 이러한 논리구성이 가능한지, 가능하다고 하더라도 과연 자회사 근로자에게 어떤 의미가 있을지 하는 의문이 있기는 하지만, 경청할 필요가 없는 것은 아니다.

www.kci.go.kr

사 등의 근로자와 양수예정회사 사이에 직접적인 근로관계가 존재하지 않는 것은 물론, 양수예정회사 등은 양도예정회사 등에 대해 사실적인 영향력만을 가지고 있을 뿐이다.

2) 해석에 의한 문제해결의 시도와 한계

이에 관한 판례는 존재하지 않고, 학설은 대부분 사용자성을 긍정하는 경향이 있다. 즉 "합병계약을 체결하고 가까운 장래에 확실하게 근로계약상의 사용자로 될 것이 예정된 기업"은 당해 노동관계에 대하여 실질적 영향력 내지 지배력을 가지고 있기 때문에 단체교섭의 상대방이 되는 사용자로 인정하는 견해,[60] "회사 합병의 과정에서 존속회사가 미리 소멸회사의 근로자나 그 소속 노동조합에 대하여 부당노동행위를 한 경우에는 그 존속회사도 사용자로 인정"된다고 보는 견해[61] 등이 여기에 해당한다. 이러한 결론은 사용자성의 인정기준을 이른바 '지배력설'에[62] 근거하여 파악하는 것에서 유래하는 것으로 추측된다.

그런데, 현대중공업판결의 판지를 여기에 적용하면, 인수예정기업이 피인수예정기업의 "근로자의 기본적인 노동조건 등에 관하여 그 근로자를 고용한 사업주로서의 권한과 책임을 일정 부분 담당하고 있다고 볼 정도로 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자"로 인정되는 것은 어려울 것으로 보인다. 피인수예정기업 근로자에 대해 인수예정자가 근로계약을 체결한 것도 아니고 지휘명령권을 행사하고 있는 것도 아니기 때문에, 근로조건의 결정과 관련하여 "그 근로자를 고용한 사업주로서의 권한과 책임을 일정 부분 담당하고 있다고 볼 정도"라고 인정되기는 어렵기 때문이다. 설사 사용자성을 인정한다고 하더라도, 유

60) 김유성, 앞의 책, 132쪽.
61) 임종률, 앞의 책, 265쪽. 김형배 교수도 같은 의견이다(앞의 책, 1081쪽).
62) 지배력설에 대한 상세한 내용 소개는 이병희, "사내하도급에서 수급인 근로자에 대한 도급인의 노조법상 사용자책임", 사법논집 제51집, 2011, 147쪽 이하 참조. 이른바 대향관계설에서는 근로삼권 행사와 관련된 노동관계 전반에 지배력을 가진 자까지 포함하여야 한다고 하여 지배력설보다 더 넓은 사용자개념을 제안하고 있다(윤애림, 『다면적 근로관계에서의 사용자의 책임』, 서울대학교 법학박사학위논문, 2003, 129쪽 이하).

www.kci.go.kr

형 3에서 살펴본 바와 같이 현행 노조법의 기본적인 틀과의 정합성 문제는 남을 것으로 보인다. 요컨대 현대중공업판결의 판지에 기한 사용자개념의 확대는 이러한 상황에서는 효과적인 해결방법이라고 보기는 어렵다.

Ⅲ. 입법적 제안에 대한 검토

1. 근로자·사용자 개념 확대에 관한 입법제안의 내용

근로자개념과 사용자개념의 확대에 대한 노동계의 요구는 지속적으로 이루어져 왔고, 이를 반영하여 국회에 다수의 입법안이 제시되어 왔다. 16대 국회에서 19대 국회인 현재에 이르기까지 지난 10여 년간 근로자 및 사용자 개념 확대를 제안한 법안은 11차례에 걸쳐서 발의되었다. 근기법만을 대상으로 한 것, 근기법과 노조법을 모두 대상으로 한 것, 노조법만을 대상으로 한 것 등으로 다양하다. 제안된 입법안들은 다음과 같다.

우선, 근기법상의 근로자 정의와 관련하여 "특정사용자의 사업에 편입되거나 상시적 업무를 위하여 노무를 제공하고 그 사용자 또는 노무수령자로부터 대가를 받아 생활하는 자",[63] "독립사업자 형태로 노무를 제공하는 자라고 하더라도 특정 사업주의 사업에 편입되거나 특정 사업주가 상시적으로 영위하는 업무를 위하여 노무를 제공하고 그 사업주로부터 대가를 얻어 생활하는 자",[64] "독립사업자 형태로 특정사업주의 사업에 필요한 노무 또는 서비스를 직접·상시적으로 제공하고 이의 대가를 받아 생활하는 자"[65] 등을 포함시키자는 안이 제시되었다. 이러한 근로자 개념의 확대는 주로 유형 1에 해당하는 범주의 자를 근로자에 포함시키

63) 16대 국회 김성조의원안 (의안번호 161647).
64) 18대 국회 홍희덕의원안 (의안번호 1804813).
65) 19대 국회 이목희의원안 (의안번호 1901510). 이목희의원안에는 새로운 정의에 따른 근로자의 인정 여부를 심의하기 위한 근로자인정심의위원회를 중앙노동위원회 산하에 설치하자는 제안도 포함된 것이 흥미롭다(제12조의2 신설).

www.kci.go.kr

고자 하는 목적으로 제안된 것이라고 할 수 있다.

이러한 안은 모두, 노무제공형태의 다양화와 보호의 필요성이 있는 노무제공자가 증가함에 따라 이러한 자들(이른바 특수형태고용종사자, 유형1)에 대해서도 노동법의 보호를 확대하겠다는 취지를 가진 제안들이다. 이 안들에 따르면 이러한 범주에 속한 노무제공자에게는 근기법이 전면적으로 적용되는 결과가 된다. 즉 경제적 종속성은 인정될 수 있지만 인적 종속성은 양적인 관점에서 일반 근로자에 비하여 상대적으로 약한 것이 명확한 노무제공자에 대해서도 해고규제 등을 포함한 근기법상의 모든 보호를 적용하게 되는 결과가 발생하게 된다.

또한 주목되는 것은 김성조의원안과 홍희덕의원안에서 근기법상 근로자성 판단요소로서 '사업에의 편입'을 들고 있다는 점이다.[66] '사업에의 편입'은 경제적 종속성을 판단하는 요소 중 하나로 상정한 것으로서, 제공된 노무가 노무제공상대방 사업의 구성요소로서 불가결하다는 점을 강조하기 위한 것으로 보인다. '사업에의 편입'은 노무제공상대방의 지휘명령권 행사 유무와 관계없이 노무제공자의 노동력을 그 사업의 필요에 따라 상시 이용할 수 있는 상태에 둘 수 있다는 의미로 일응 해석될 수 있을 것이지만, 판례에서 한 번도 언급되지 않은 개념으로서 그 의미가 명확하지 않아 논란의 여지가 있다. 또한 그것이 과연 근기법상 근로자성 판단을 위한 독자적인 기준이 될 수 있는지도 의문이다.[67]

다음으로, 사용자개념과 관련하여서 "근로계약 체결의 형식적 당사자가 아니라고 하더라도 당해 근로자의 근로조건 등의 결정에 대하여 실질적인 지배력 또는 영향력이 있는 자",[68] "근로계약의 체결 여부와 상관없이 당해 근로자의 근로조건 등의 결정에 대하여 실질적인 지배력 또는

---

66) 후술하는 바와 같이 이 표현은 노조법상 근로자 정의에 관한 입법안에서도 다수 등장한다.

67) '사업에의 편입'이 경제적 종속성을 전제로 한 개념이라고 하더라도 '사업에의 편입'은 오히려 노조법상 근로자 개념에 상대적으로 친한 것이라고 할 수 있다. 노조법은 단체교섭 및 단체협약을 통한 근로조건의 집단적 결정을 내용으로 하는 시스템이기 때문에 '사업에의 편입'은 노조법이 상정하고 하는 조직적·집단적 노무공급관계의 전제로서 작용할 수 있기 때문이다.

68) 16대 국회 김성조의원안 (의안번호 161647호).

www.kci.go.kr

영향력이 있는 자",[69] "근로계약체결의 당사자가 아니라고 하더라도 근로조건 등의 결정에 대하여 실질적인 지배력 내지 영향력이 있는 자"[70]를 포함하는 제안이 이루어져왔다. 명시적인 근로계약관계가 없는 경우에도 근로조건 등의 결정에 "실질적인 지배력 또는 영향력"이 있는 경우에 대해서 사용자로서의 지위를 인정하는 것이다. 이른바 지배력설에 입각한 이러한 제안은 앞에서 살펴본 현대중공업판결의 판지에서 제시한 사용자성보다 더 넓은 범주의 자에 대해 사용자성을 인정하고 있다는 점이 주목된다.

노조법상 근로자 개념과 관련하여서는, "근로계약을 체결하지 않은 자라 하더라도 특정 사용자의 사업에 편입되거나 상시적 업무를 위하여 노무를 제공하고 그 사용자 또는 노무제공을 받은 자로부터 대가를 얻어 생활하는 자",[71] "계약의 명칭이나 형식에 관계없이 노무제공 상대방에 대하여 노무를 제공하고, 수입의 전부 또는 상당부분을 그 사업주에 의존하여 생활하는 자, 기타 대통령령이 정한 요건을 갖춘 자로서 이 법에 의한 사회적 보호의 필요성이 있는 자",[72] "특정사용자의 사업에 편입되거나 상시적 업무를 위하여 노무를 제공하고 그 사용자 또는 노무수령자로부터 대가를 얻어 생활하는 자",[73] "근로계약을 체결하지 않은 자라 하더라도 특정 사용자의 사업에 편입되거나 상시적 업무를 위하여 노무를 제공하고 그 사용자 또는 노무제공을 받은 자로부터 대가를 얻어 생활하는 자 및 실업상태에 있는 자나 구직중인 자",[74] "계약형식과 관계없이 자신이 아닌 다른 자의 업무를 위하여 노무를 제공하고 해당 사업주 또는 노무수령자로부터 대가를 받아 생활하는 자 및 일시적인 실업상태에 있거나 구직중인 자",[75] "자신이 아닌 다른 사업주의 업무를 위하여 노무를 제공하고 그 사업주 또는 노무제공을 받은 자로부터 대가를

69) 17대 국회 단병호의원안 (의안번호 170169호).
70) 18대 국회 홍희덕의원안 (의안번호 1804813호).
71) 17대 국회 단병호의원안 (의안번호 175246호).
72) 17대 국회 우원식의원안 (의안번호 176119호).
73) 17대 국회 홍희덕의원안 (의안번호 1804812호).
74) 17대 국회 홍영표의원안 (의안번호 1811856호).
75) 19대 국회 김경협의원안 (의안번호 1901589호).

www.kci.go.kr

받아 생활하는 자 및 실업상태에 있거나 구직 중인 자"[76] 등으로 제안되고 있다. 대부분의 안에서는 기타 노조법에 의한 보호의 필요성이 있는 자도 추가하고 있다.

이상의 근로자개념은 근기법상 근로자개념에 대한 입법제안과 마찬가지로 유형 1에 속하는 형태의 근로, 즉 노무제공으로 생활하는 자에 대해 노조법상의 근로자 지위를 부여하려는 취지라는 것을 명확히 알 수 있다.

한편, 노조법상 사용자개념과 관련하여서는 "근로계약 체결의 형식적 당사자가 아니더라도 당해 노동조합의 상대방으로서의 지위를 인정할 수 있거나 근로자의 근로조건에 대하여 실질적인 지배력 또는 영향력이 있는 자",[77] "근로계약 체결의 형식적 당사자가 아니라고 해도 해당 노동조합의 상대방으로서의 지위를 인정할 수 있거나 또는 근로자의 근로조건에 대하여 실질적인 지배력 또는 영향력이 있는 자 및 사내하도급의 도급사업주",[78] "근로계약 체결의 형식적 당사자가 아니더라도 당해 노동조합의 상대방으로서의 지위를 인정할 수 있거나 근로자의 근로조건에 대하여 실질적인 지배력 또는 영향력이 있는 자",[79] "당해 노동조합의 상대방 지위를 인정할 수 있거나 근로자의 근로조건에 대하여 실질적인 지배력이 있는 자",[80] "근로계약 체결의 당사자가 아니라고 하더라도 당해 노동조합의 상대방으로서의 지위를 인정할 수 있거나 근로자의 근로조건에 대하여 실질적인 지배력 또는 영향력이 있는 자"[81]를 현행 사용자 정의 속에 포함시키는 것을 제안하고 있다.

모두 이른바 지배력설에 근거한 제안들로, 현대중공업사건 대법원 판지가 제안한 사용자개념보다 광범위한 사용자개념을 제시하고 있는 점이 주목된다.

---

76) 19대 국회 심상정의원안 (의안번호 1900464호).
77) 17대 국회 단병호의원안 (의안번호 175318호).
78) 17대 국회 홍희덕의원안 (의안번호 1804812호).
79) 17대 국회 홍영표의원안 (의안번호 1811853호).
80) 19대 국회 김경협의원안 (의안번호 1901589호).
81) 19대 국회 심상정의원안 (의안번호 1900464호).

www.kci.go.kr

2. 입법안에 대한 평가

이상의 입법안들은 근로자개념과 관련하여서는 이른바 특수고용형태종사자를 포섭하는 내용을 담고 있고, 사용자개념과 관련하여서는 지배력설에 따라 근로자의 근로조건에 대하여 "실질적인 지배력 또는 영향력이 있는 자"를 사용자 정의에 포함하여 주로 사내하도급 상황에서 원청기업의 사용자성을 인정하려는 취지를 가지고 있다고 평가할 수 있다. 이러한 안들에 따르면 근로자 범위나 사용자 범위는 대폭적으로 확대되어 근로자보호에 큰 도움이 될 것임은 분명하다. 특히 앞에서 제시한 유형 1, 2, 3, 4 모두에 대해 근로자성과 사용자성을 용이하게 인정할 수 있는 가능성을 부여할 수 있다. 그럼에도 불구하고, 위의 입법안과 같이 근로자 및 사용자개념을 확대하고자 할 때에는 다음과 같은 점이 반드시 고려되어야 할 필요가 있을 것으로 보인다.

첫째, 근기법과 관련하여 입법안들과 같은 방향으로 개정이 이루어진다면 근기법 내부 조항 상호간에 충돌이 발생할 가능성이 많다. 예컨대 근로조건의 명시의무(법 제17조; 제114조)와 같이 근로계약을 전제로 규정되어 있는 조항이 "근로조건 등에 대해 실질적인 지배력 또는 영향력이 있는 자"(이하 '확대된 사용자')에게 부과되는지, 부과된다면 확대된 사용자는 어떤 방식으로 근로조건 명시의무를 이행할 수 있는지가 문제될 수 있다. 또한 해고 제한과 관련한 규정들은 확대된 사용자에게도 적용되게 되는데, 이 경우 해고권을 가진 사용자는 근로계약을 체결한 사용자인가 아니면 확대된 사용자인가, 해고된 근로자는 근로계약을 체결한 사용자를 대상으로 부당해고구제신청을 하여야 하는가 아니면 확대된 사용자를 대상으로 하여야 하는가, 확대된 사용자, 예컨대 원청사업주에게 정리해고사유가 발생할 경우 하청기업 근로자를 대상으로 해고대상자를 선별할 수 있는가 등이 문제될 수 있다. 임금지급과 관련하여 임금체불책임은 확대된 사용자도 부담하는가, 임금체불의 형사책임은 누가 부담하여야 하는가 등이 문제될 수 있고, 도급사업에 대한 임금지급을 정한 제44조, 건설업에서의 임금지급연대책임을 규정한 제44조의2, 건설업의 공사도급에서의 임금에 관한 특례를 정한 제44조의3은 사용자개념을 확대

www.kci.go.kr

할 경우 사용자책임에 반하거나 불필요한 내용을 담고 있는데, 이 조항의 효력은 어떻게 되는지가 문제될 수 있다. 취업규칙과 관련하여서도 형식적인 근로계약을 체결한 사용자의 취업규칙이 적용되는가 아니면 확대된 사용자의 취업규칙이 적용되는가, 취업규칙을 불이익변경할 때 동의의 주체가 되는 근로자의 과반수는 근로계약을 체결하고 있는 근로자를 의미하는가, 확대된 사용자의 영향 하에 있는 근로자를 의미하는가 등의 문제가 발생할 수 있다 또한 근기법 위반의 벌칙과 관련하여서도 누구에게 적용되는지, 양벌규정(제115조)은 확대된 사용자에게도 적용되는지 등 근기법 내부에서 다양한 문제가 발생할 수 있다.

노조법과 관련하여서도 상대적으로 적기는 하지만 유사한 문제가 발생한다. 지금까지 노조법은 노동조합과의 단체교섭을 통하여 단체협약에 의한 근로조건의 집단적 결정을 근간으로 구성, 운영되어 왔는데, 입법안에서 제시하는 바와 같이 근로자개념과 사용자개념을 확대한다면 이러한 근간이 흔들릴 우려를 배제할 수 없다. 예를 들어, 근로계약을 체결하지 않고 위임계약이나 도급계약을 체결하고 있는 경우 또는 명시적인 계약을 체결하지 않고 노무제공을 하는 자에게 노조법상 근로자성을 인정한다면, 이들이 체결한 단체협약은 규범적 효력을 가지는가, 즉 노조법 제33조는 단체협약의 규범적 효력이 취업규칙 또는 "근로계약"에 미치도록 규정하고 있는데, 도급계약이나 위임계약을 체결한 경우 이들 계약에 대해서도 단체협약의 규범적 효력이 미칠 수 있는지가 문제될 수 있다. 또한 단체협약 작성 주체는 확대된 사용자인가 아니면 근로계약을 체결한 사용자인지도 문제될 수 있다.

요컨대 근기법이나 노조법상 사용자개념을 확대하고자 할 경우에는 우선 근기법 내부 그리고 노조법 내부에서 충돌되거나 모순되는 규정을 정비하여야 한다. 그러나 지금까지 제시된 입법안에서는 이러한 고려가 결여되어 있다.

둘째, 근기법은 근로자의 최저근로조건을 보호하기 위해 기본적으로 벌칙의 적용을 전제로 하여 그 이행을 담보하는 체제로 이루어져 있다. 그리고 그 벌칙의 대상은 사용자가 된다. 그런데, 사용자개념을 입법안과 같이 확대하면 죄형법정주의와의 관계에서 문제가 발생할 가능성을 배제

www.kci.go.kr

할 수 없다. '사업에의 편입', '근로조건 등에 대해 실질적인 지배력 또는 영향력'이라는 개념은 명확성 원칙과 관련하여 문제될 수 있기 때문이다. 또한 이로 인해 법원이 사용자성이나 근로자성 판단에 있어 소극적이고 엄격한 태도를 취할 수밖에 없도록 하는 역효과를 초래할 수도 있다.

셋째, 사용자개념을 정의에 의해 확대하면 앞에서 지적한 바와 같이 중첩적인 사용자가 일상적으로 발생하게 되는데, 그 경우 사용자간에 책임은 어떻게 분배하여야 하는지가 명확하게 제시되어 있지 않다. 그러한 상황에 관한 판례법리도 형성되어 있지 않은 상태라는 점을 고려하면 이 문제를 정면에서 규율하는 내용이 포함되어 있어야 하지만, 입법기술적으로 용이한 것으로 보이지는 않는다. 특히 형사책임이 문제될 수 있을 것이다.

넷째, 근기법상 사용자개념을 입법안들과 같은 내용으로 확대할 경우 고용과 사용의 분리를 전제로 한 근로자파견법이나 직업안정법에 기한 근로자공급사업은 사실상 형해화 된다는 점도 고려하여야 한다. 사용자개념을 입법안과 같이 확대할 경우 근로자파견사업의 사용사업주나 근로자공급사업에서의 사용사업주는 바로 근기법상의 사용자가 되기 때문이다. 입법안들에 따르면 그 입법취지를 넘어서 근로자개념이나 사용자개념의 외연이 지나치게 확대되는 상황을 피하기 어렵다.

다섯째, 사용자개념이 확대되면 적용대상이 대폭 확대되고, 근로자 외연이 대폭 확대되어 관련 분쟁이 많이 발생할 수밖에 없다. 2009년의 경우 고용노동부 근로감독관의 근로기준법 위반 신고사건은 33만 여건이고, 이 중 임금체불사건이 32만 6천건으로 대부분을 차지하고 있다.[82] 사용자개념이 확대되면 관련 분쟁이 대폭적으로 증대할 것이 확실하다. 기존의 노동분쟁해결시스템을 전제로 한다면 분쟁해결을 위한 행정부담이 과도하게 증가하여 노동분쟁을 합리적으로 처리하는 것을 기대할 수는 없다. 분쟁해결의 지연은 분쟁의 대규모화, 사회문제화로 이어질 가능성이 많다. 그러나 입법안들에서는 이 문제에 대한 고민을 찾을 수 없다.

마지막으로, 근기법상의 근로자개념이나 사용자개념의 확대는 다른 법률과의 정합성을 고려하면서 접근하여야 한다. 2013년 12월 현재 근기법

82) 고용노동부 내부자료 참조.

www.kci.go.kr

상의 근로자개념을 그대로 차용하면서 법의 적용대상을 정하고 있는 법률은 17개에 달하며,[83] 근기법상 사용자개념을 그대로 차용하고 있는 법률은 '근로자참여 및 협력증진에 관한 법률', '근로자퇴직급여보장법', '장애인차별금지 및 권리구제에 관한 법률', '최저임금법' 등이 있다. 그 밖에 현행법에서 '근로자'라는 개념을 사용하고 있는 법률은 156개에 이르고, '사용자'라는 개념을 사용하고 있는 법률은[84] 135개에 이를 정도로 광범위하게 사용되고 있다. 근로자 및 사용자개념을 확대할 경우 근기법이나 노조법 자체의 내부에서도 해결되기 어려운 문제가 발생한다는 점을 감안하면, 근기법상 근로자개념을 전제로 하고 있는 법률들에서도 근로자나 사용자개념 확대와 관련하여 상충은 없는지, 정합성은 유지되는지 여부를 구체적으로 면밀하게 검토할 필요가 있다.

이와 같이 최근 급속하게 대두되고 있는 다양한 노무제공자에 대해 보호를 제공하고 사내하도급이나 자회사 등을 통해 이익은 누리면서도 책임은 부담하지 않는 불합리한 상황을 개선하기 위한 시도로서, 근기법과 노조법의 근로자개념과 사용자개념을 일률적으로 확대하는 방법에는 신중할 필요가 있다. 오히려 문제의 유형에 따른 개별적인 접근방식이 문제 상황을 명확히 하고 상황에 적합한 해결을 모색하는 방안으로 생각된다. 이하에서는 그러한 방법을 모색할 때 고려하여야 할 방향만 간단히 제시하고자 한다.

---

83) '고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률', '고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률', '건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률', '근로자참여 및 협력증진에 관한 법률', '근로자퇴직급여보장법', '산업안전보건법', '산업재해보상보험법', '석면피해구제법', '선원법', '임금채권보장법', '장기등 이식에 관한 법률', '장애인고용촉진 및 직업재활법', '진폐의 예방과 진폐근로자의 보호 등에 관한 법률', '최저임금법', '근로복지기본법', '기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률', '고용보험법'.

84) 유사한 개념으로 '사업주'라는 개념을 사용하고 있는 법률은 51개이다.

www.kci.go.kr

Ⅳ. 새로운 접근을 위한 출발점

1. 유형 1과 관련하여

경제적 종속 하에서 노무를 제공하면서 생활하는 자에 대한 보호와 관련하여서는 종래 학계에서 논의되어 온 특수형태고용종사자에 대한 보호 방안을 적극적으로 고려할 필요가 있다.[85] 이에 대해서는 다양한 비판이 존재할 수 있다. 특수형태고용종사자라는 별도의 개념을 새로이 도입하는 것은 근기법상 근로자와의 경계 확정 문제가 새로이 발생한다는 점, 제3의 영역으로서 특수형태근로종사자가 시민법의 수정원리로서 노동법이 등장할 때의 근로자집단과 비교하여 양적·질적으로 유사한 사회적 실체를 갖추고 있는지 여부, 보호의 내용과 수준을 어떻게 정하여야 하는지에 대한 사회적 합의가 이루어지지 않은 점 등에서 의문이 제기될 수도 있다. 그러나 현행 법상태를 전제로 한다면, 이들에 대해서 실질적으로 아무런 노동법적인 보호도 제공하지 못한다는 것은 명확하다는 점을 고려하여, 이들 유형의 노무제공자 보호에 초점을 둔 방안을 마련할 필요가 있다. 그 방식은 특별법을 제정하는 방법도 있을 수 있고, 근기법 내에 포섭시키면서 성질상 부합하지 않는 일부 조항의 적용을 배제하는 방법도 있을 수 있다. 집단법과 관련하여서도 노조법에 편입시켜 일부 조항의 적용을 배제하거나 또는 특별법 속에서 집단적 노사관계에 관한 사항을 규율하는 방식을 취하는 것도 가능할 것이다.

---

85) 강성태, “특수고용직의 노동법적 보호”, 『노동정책연구』 제7권 제3호, 한국노동연구원, 2007, 93-117쪽; 김영문, “특수형태근로종사자의 집단적 이익대변구조”, 『법학연구』 제32호, 전북대학교 법학연구소, 2011, 207-263쪽; 도재형, “사법과 입법의 사각지대, 특수형태근로종사자”, 『노동법연구』 제34호, 서울대학교 노동법연구회, 2013, 197-244쪽; 박지순, 『독일의 유사근로자의 유형과 노동법상 지위에 관한 연구』, 한국노동연구원, 2005; 윤애림, “산재보험법의 특수형태근로종사자 특례제도의 문제점과 대안”, 『노동법연구』 제33호, 서울대학교 노동법연구회, 2012, 47-91쪽; 이승욱, “특수형태근로종사자의 법적 규율을 위한 입법적 모색”, 『노동법연구』 제19호, 서울대학교 노동법연구회, 2005, 199-264쪽; 조경배, “독립노동과 유사근로자 그리고 위장자영인”, 『민주법학』 제25권, 민주주의법학연구회, 2004, 298-335쪽 등.

www.kci.go.kr

이러한 방안을 모색함에 있어서는 유형 1에 속하는 노무제공자는 일반 근로자와 마찬가지의 경제적 종속성을 갖추고 있는 반면, 인적 종속성의 측면에서는 일부 요소가 탈락되어 있다는 점이 반영되어야 할 것이다.

2. 유형 2와 관련하여

원청기업이 하청기업의 근로자에 대해 실질적으로 지휘명령권을 행사하는 경우, 현행법에 따르면 묵시적 근로계약법리나 법인격부인법리를 통하여 원청기업의 근로자성을 전면적으로 인정받거나 또는 현대중공업 대법원 판지의 확장이 가능하다면 최소한 단체교섭의 상대방으로서 원청기업에 대해 교섭의무를 부과할 수 있다. 그러나 묵시적 근로계약관계의 성립이 부정되거나 현대중공업 대법원 판결의 확대해석이 불가능한 경우에는 하청기업근로자는 원청기업에 대해 노동법상 책임을 추급할 수 있는 방법을 찾기 어렵다. 근로자파견법상 불법파견에 대해서는 사용사업주에게 고용의무를 부과하고 있는 등 제도적 방안(제6조의2)이 마련되어 있고 아직 그것을 둘러싼 여러 가지 법적 쟁점들이 해소되지 않은 상태이기 때문에, 근로자파견법 제6조의2와 관련한 법리의 형성과 전개를 통해 불법파견 내지 위장도급의 문제가 해소될 수 있는지에 관하여 향후 판례법리의 형성을 기다려볼 필요가 있다. '하도급근로자 보호 등에 관한 법률'을 제정할 것인지도 도급과 파견의 구별기준을 둘러싼 쟁점과 문제점이 좀 더 부각되고 구체화될 때까지는 신중할 필요가 있을 것이다.

다만 현대중공업 대법원 판결이 제시한 사용자개념의 기준이 미치는 범위와 책임부담의 분배와 관련하여서는 적극적인 입법적 개입이 필요할 것으로 보인다. 즉 현대중공업 대법원 판결은 지배개입의 부당노동행위에 관한 사건이지만, 그 판지를 단체교섭거부를 포함하여 부당노동행위 전반으로 확대하고, 중첩적 사용자책임을 어떻게 배분할 것인지에 대한 규정을 부당노동행위제도에 명시하는 방안을 적극적으로 고려할 필요가 있을 것으로 보인다.

www.kci.go.kr

3. 유형 3과 관련하여

지주회사 또는 모회사의 자회사에 대한 지배는 주식보유를 통해 법적인 지배력이 인정된다. 그리고 지주회사나 모회사의 성격상 지주회사나 모회사의 지배력은 자회사의 해산도 초래할 정도로 강력하다. 따라서 지주회사나 모회사의 경영방침이나 인사정책이 자회사를 통해서 간접적으로 자회사 근로자의 근로조건에 대한 지배력으로 이어지는 것은 당연하다고 할 수 있다. 바꾸어 말하면 지주회사나 모회사는 자회사 근로자의 근로조건이나 고용에 형식적으로는 간접적이지만 실질적으로는 직접적으로 관여할 수 있다는 것이다. 그러나 앞에서 본 바와 같이 현행법 하에서는 현대중공업 대법원 판결의 판지를 확대해석 한다고 하더라도 자회사 근로자가 지주회사나 모회사에 대해 근기법상 사용자 책임을 추급하거나 단체교섭을 요구하는 것은 용이하지 않다.

영국에서는 '관련사용자'(associated employer)라는 개념을 도입하여 이 문제의 해결을 시도하고 있다.[86] 1996년 고용권법(Employment Rights Act 1996) 제231조 및 1992년 노동조합 및 노동관계통합법(Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992) 제297조는 '관련사용자'라는 개념으로 사용자개념을 확대하고 있다.[87] 이에 따르면 일방이 타

---

86) 상세한 것은, Daekin & Morris, Labour Law 5th ed., Hart Publishing, 2009, p.194 이하.

87) 영국에서 관련사용자는 노동법상의 모든 책임을 부담하는 것이 아니고 명시적으로 규정되어 있는 책임만을 부담하도록 되어 있다. 여기에는 전직시 근속기간의 통산(고용권법 제218조 (6)), 정리해고의 인원삭감의 필요성 판단에 관련회사 전체를 대상으로 판단하고(고용권법 제139조 제1항) 정리해고가 불공정할 경우 복직범위는 관련사용자 전체를 대상으로 하는 점(Williams v. Compare Maxam Ltd., [1982] IRLR 83 (EAT)), 불공정해고시 원직복귀 또는 재고용명령의 수규자(고용권법 제115조 (1)), 최저임금 산정시 재직기간이 6월 미만이면 통상의 최저임금을 받을 수 없는데 이 때 관련사용자의 재직기간 포함(1999년 최저임금법(National Minimum Wage Rate Regulations) 제13조 (2)), 동일가치노동 동일임금 원칙의 적용에서 비교대상자 범위를 관련사용자의 근로자까지 확대(동일임금법(Equal Pay Act) 제1조 (1)), 단체교섭시 관련사용자의 정보제공의무(노동조합 및 노동관계통합법 제181조 (2)), 법정노조승인절차개시요건에서 사용자수 산정시 관련사용자의 근로자도 포함(노

www.kci.go.kr

방에 의해 직접적·간접적으로 지배받는 회사 또는 양자가 제3자에 의해 직접적·간접적으로 지배받는 회사는 관련사용자로 본다고 규정하고 있다. 여기에서 '지배'(control)의 의미에 대해 판례는 실질적 지배 또는 사실적 지배로는 충분하지 않고 지배하는 자가 주식의 과반수를 소유하고 있는 경우로 한정하고 있다.[88] 우리나라의 지주회사나 모회사는 자회사 주식의 과반수를 보유하여야 하기 때문에(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제1의2호, 동법시행령 제2조 제2항; 상법 제342조의2 제1항 참조), 영국법의 '관련사용자' 요건을 충족하고 있다.

1999년 공정거래법의 개정에 의해 지주회사가 합법화되고, 2001년, 2004년, 2007년의 개정을 통하여 지주회사로의 전환이 용이해져 지주회사가 널리 설립되고 있음에도 불구하고 법개정 과정에서 지주회사 설립이 노동관계에 미치는 영향에 대한 입법적 검토는 전혀 행해지지 않았다. 지주회사나 모회사는 '간접적인 지배력'을 통해 자회사 근로자의 근로조건에 영향을 미칠 수 있으나, 앞에서 본 바와 같이 현행 법리 하에서는 자회사 근로자 보호나 집단법 관련 권리의 행사가 사실상 어렵다는 점을 고려할 때 이에 관한 제도 마련이 시급한 입법과제라고 할 수 있다.

4. 유형 4와 관련하여

인수나 합병 등을 예정하고 있는 회사가 상대방 회사에 대해 근로조건의 저하나 인원삭감을 계약성립의 조건으로 내세우는 경우와 같이 기업변동과 관련하여 인수대상기업 근로자에 '사실상의 지배력'을 미칠 수 있

동조합 및 노동관계통합법 부칙 A, 제1조) 등이 있다.

88) Secretary of State for Employment v. Newbold and Joint Liquidators, [1981] IRLR 305 (EAT). 이 사건에서 고용항소법원은 "지배라 함은 주주총회에서 행사되고 주식에 부여된 의결권의 과반수에 의한 지배를 의미한다. 그것은 당해 기업이 실제로 어떻게 또는 누구에 의해 실제로 운영되고 있는지 여부를 말하는 것이 아니다"고 판시하고 있다. 이와 같은 판례의 형식적인 입장에 대해서는 경제적 실체관계를 제대로 반영하지 못하고 있다는 비판이 제기되고 있다(H. Collins, Ascription of Legal Responsibility to Groups in Complex Patterns of Economic Integration, Modern Law Review 53 (1990), p. 744).

www.kci.go.kr

다. 앞에서 살펴본 바와 같이 학설에서는 이른바 지배력설의 입장에서 인수대상기업의 사용자로 포섭하고 있는 견해가 많으나, 대법원은 일반적인 지배력설과는 다른 사용자확대기준을 제시하였기 때문에, 이 기준을 적용하면 인수나 합병 또는 양수 예정 기업이 행사하는 사실상의 지배력에 대해 대상기업의 근로자를 보호할 수 있는 방안은 존재하지 않는다고 하여도 과언이 아니다. 이 문제를 포함하여, 회사분할제도의 도입 등 회사법제도가 급속하게 변화하고 있는 사정을 고려하면서, 기업조직 재편시 근로관계를 둘러싼 제반 문제에 관한 명문의 규정을 마련할 필요가 있다.

주제어: 사용자개념, 근로자개념, 특수형태고용종사자, 직접적 지배력, 간접적 지배력, 사실상 지배력

www.kci.go.kr

참고문헌

강성태, “사내하도급 삼부작 판결의 의의”, 『노동법학』 제35호, 한국노동법학회, 2010.

강성태, “특수고용직의 노동법적 보호”, 『노동정책연구』 제7권 제3호, 한국노동연구원, 2007.

강신철, “비정규직 범위와 규모에 관한 새로운 고찰”, 『산업관계연구』 제22권 제1호, 한국노사관계학회, 2012.

김영문, “특수형태근로종사자의 집단적 이익대변구조”, 『법학연구』 제32호, 전북대학교 법학연구소, 2011.

김유성, 『노동법 II』, 법문사, 1999.

김재훈, “특수형태근로 종사자에 대한 법적 보호방안”, 『노동법연구』 제13호, 2002.

김형배, 『노동법(22판)』」, 박영사, 2013.

김형배, 『노동법』, 박영사, 2006.

도재형, “사법과 입법의 사각지대, 특수형태근로종사자”, 『노동법연구』 제34호, 서울대학교 노동법연구회, 2013.

박수근, “레미콘운송기사와 경기보조원의 근로자성에 관한 검토”, 『노동법학』 제14호, 2002.

박수근, “특수고용형태의 근로자성” 『한국노동법학회 자료집』, 2001.12.

박제성·박지순·박은정, 『기업집단과 노동법』, 한국노동연구원, 2007.

박지순, 『독일의 유사근로자의 유형과 노동법상 지위에 관한 연구』, 한국노동연구원, 2005.

윤애림, “산재보험법의 특수형태근로종사자 특례제도의 문제점과 대안”, 『노동법연구』 제33호, 서울대학교 노동법연구회, 2012.

이병태, “노동법상 노동자의 개념”, 법률신문 제1217호, 1977.8.

이병희, “사내하도급에서 수급인 근로자에 대한 도급인의 노조법상 사용자책임”, 『사법논집』 제51집, 2011.

이승욱, “특수형태근로종사자의 법적 규율을 위한 입법적 모색”, 『노동법연구』 제19호, 서울대학교 노동법연구회, 2005.

www.kci.go.kr

이철수, “사내하도급의 실태와 법적 대응”, 『노동법의 이론과 실천, 신인령선생님정년기념논문집』, 박영사, 2008.
임종률, 『노동법(11판)』, 박영사, 2013.
조경배, “독립노동과 유사근로자 그리고 위장자영인”, 『민주법학』 제25권, 민주주의법학연구회, 2004.
최영호, “계약근로형 노무공급자의 근로자성”, 『노동법연구』 제13호, 2002.

木南直之, “勞働組合法上の使用者概念と團交事項”, 日本勞動法學會誌 119호, 2012.
道幸哲也, “親會社の團交應諾義務一なんのための團交權”, 季刊勞働法 216호, 2007.
Daekin & Morris, Labour Law 5th ed., Hart Publishing, 2009.

www.kci.go.kr

<Abstract>

Legal Issues and Proposals on the Expansion of the Concept of Employer and Employee in Labor Law

Lee, Sung-Wook*

In recent years, as diversity in employment type proliferates, demands for amendment to labor law provisions which define the concept of employer and employee are being bought up. To study the validity of this argument, this paper begins with dividing the conditions where the concept of employer and employee matters in labor law into four categories. These are; first, the conditions where the question of so-called economically dependent contractor, who works in situations of which some of typical characteristics of traditional employer-employee relation (e.g. employer's direct control and command over the employee) are dropped out, is an employee or not arises; second, the conditions where user company or principal company formally has direct control or direction over third party company's employee while avoiding all or some of responsibilities in labor law, legally or illegally, like in dispatched or temporary agency employee, or in-site subcontracting employee of the subcontractor; third, the conditions where the parent company determines indirectly terms and conditions of employment of the subsidiary company in business groups but abdicates responsibilities of labor law by taking advantage of the difference in formal legal entity; fourth, the conditions where in the event of business changes, the prospect acquisition company has de facto influence on the terms and

* Professor of Law, Ewha Womans University

www.kci.go.kr

conditions of employment of employee in target company while taking absolutely no responsibility in labor law.

This paper argues that it is impossible to solve legal problems that occur in these four conditions by amending the definition provisions of employer and employee in the Labor Standards Act and the Trade Unions and Labor Relations Adjustment Act. It is because when approaching the problems in this way, contradiction of other provisions in the Labor Standards Act and the Trade Unions and Labor Relations Adjustment Act occurs, which would result in inconsistency in other laws.

To settle these problems reasonably, instead of amending employer and employee definition provisions of the Labor Standards Act and the Trade Unions and Labor Relations Adjustment Act, it is necessary to clearly distinguish between special issues of each category, and to seek separate solutions in accordance with each condition.

Key words: economically dependent contractors; concept of employer; concept of employee; direct, indirect, or de facto influence on the terms and conditions of employment

www.kci.go.kr